

طبيعة المسؤولية الناجمة عن الإخلال بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد (دراسة مقارنة)

الباحثة : أميرة بخيت علي مبارك الكثيري

و

د. رغيد عبد الحميد فتال

كلية القانون- جامعة عجمان

تاريخ التسليم: 2025/4/20 تاريخ القبول: 2025/5/9

THE NATURE OF LIABILITY ARISING FROM BREACH OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE STAGES PRECEDING THE CONTRACT

(Comparative study)

Researcher: Ameera Bakheet Ali Mubarak AlKatheeri

&

Dr. Raghid Abdulhamid Fattal

College of Law - Ajman University

ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المسؤولية الناجمة عن الإخلال بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد، وتكمن أهمية هذه الدراسة في معالجة القصور التشريعي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي في هذا الجانب، وقد انتهجت المنهج التحليلي والمقارن لتحليل نصوص القانون الإماراتي ومقارنته بالقانون والفقه المقارن، وفي هذا الصدد اخترت نصوص القانون المدني الأردني، أخذاً في الاعتبار بتأثر القانون المدني الإماراتي بهذا القانون، ولتحديد مدى توافقه أو اختلافه مع موقف المشرع الإماراتي بخصوص تنظيمه لمبدأ حسن النية في العقد بصفة عامة، وتنظيمه لموضوع هذه الدراسة بصفة خاصة. وفي المقابل لذلك، اخترت مقارنة القانون المدني الإماراتي بأحكام القانون المدني المصري، أخذاً في الاعتبار بأن أغلب أحكام القانون المدني المصري مستنبطة من القانون المدني الفرنسي، مع الاطلاع على تحديث مرسوم أكتوبر 2016. كما ذكرت بعض القوانين والأنظمة الأجنبية في هامش بعض الصفحات كالقانون المدني الإيطالي، ومبادئ توحيد قواعد التجارة الدولية، ومبادئ اليونيدروا في معرض اطلاعي على البحوث والرسائل العلمية ذات الصلة المباشرة بالموضوع بهدف الاستفادة منها.

وقد تم التوصل في هذه الدراسة بأن مبدأ حسن النية في العقود من النظام العام، وبأن أساس التزام الأطراف بهذا المبدأ خلال المراحل السابقة على التعاقد يرجع إلى مضمون وطبيعة هذا المبدأ، كما تم التوصل إلى نتيجتين هامتين بشأن الخلاف الفقهي الحاصل في تحديد طبيعة المفاوضات، أما النتيجة الأولى فهي متعلقة بطبيعة المفاوضات الصريحة المصحوبة باتفاق مكتوب ينظم عملية وإجراءات التفاوض القائمة بين الطرفين؛ حيث تعتبر طبيعة هذه المفاوضات عقدية بموجب هذا الاتفاق، ومن ثم تطبق بشأنها قواعد المسؤولية العقدية، أما النتيجة الثانية فهي بخصوص المفاوضات غير المصحوبة باتفاق مكتوب وصريح ينظم عملية وإجراءات التفاوض بشأن عقد معين، والتي تكتسب الطبيعة العقدية بموجب ما يسمى بعقد

التفاوض الضمني؛ والذي قد ينشأ بين الطرفين بمجرد صدور إيجاب بالتفاوض من أحد الأطراف للآخر يعبر فيه عن رغبته الجادة في التفاوض معه بشأن عقد معين، فيقترن بهذا الإيجاب قبول مطابق من الأخير، أو في الحالة التي تصبح فيها هذه المفاوضات منتظمة؛ ومستمرة مدة معقولة من الزمن؛ ومتقدمة بحيث تصل المفاوضات إلى أقرب مستوى لانعقاد العقد النهائي بما يعكس وجود نية مشتركة وجادة بين الطرفين في إجراء تنظيم تعاقدى للمفاوضات الجارية بينهما؛ أو في الحالة التي يصدر فيها أي تصرف أو فعل مشترك من الطرفين يمكن أن يستدل منه على وجود اتفاق ضمني وجاد بينهما على التفاوض بشأن عقد ما، ففي مثل هذه الحالات، تعتبر طبيعة المفاوضات غير المصحوبة بعقد تفاوض عقدية، وعلى أساس ذلك تطبق بشأنها قواعد المسؤولية العقدية، وفيما عدا ذلك تعتبر المفاوضات مجرد أعمال مادية لا ترتب أية آثار قانونية، ومن ثم تطبق بشأنها قواعد المسؤولية التقصيرية.

وفي هذا الصدد، يتضح عدم مواكبة المشرع الإماراتي للتطور الحاصل في بعض التشريعات الغربية التي تفرض صراحةً في نصوصها على الأطراف الالتزام بحسن النية في مرحلتى المفاوضات وإبرام العقد. كما يلاحظ وجود ازدواجية في تطبيق أحكام المسؤولية القانونية على المفاوضات في القضاء الإماراتي، حيث يطبق على المفاوضات غير المصحوبة بعقد تفاوض صريح أحكام المسؤولية التقصيرية بغض النظر عن وجود عقد تفاوض ضمني بين الطرفين من عدمه، بينما يطبق على المفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض صريح أحكام المسؤولية العقدية. كما نرى بأن كل ما تم التوصل إليه بخصوص أصل وطبيعة مرحلة المفاوضات ينسحب أيضاً إلى مرحلة إبرام العقد، باعتبارها مرحلة تكميلية يتم فيها استكمال ما تم التوصل إليه في مرحلة المفاوضات. وتوصي الدراسة ببعض المواد القانونية التي تتطلع الباحثة إيرادها في قانون المعاملات المدنية الاتحادي لتدارك القصور التشريعي المتمثل في عدم تنظيم مبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد.

الكلمات الدالة: مبدأ حسن النية، المفاوضات، إيجاب، عقد تفاوض، مسؤولية.

Abstract

The study aimed to identify the nature of liability arising from breaches of the principle of good faith in the pre-contractual stages. The importance of this study lies in addressing the legislative shortcomings in the Federal Civil Transactions Law in this regard. I adopted an analytical and comparative approach to analyze the texts of the UAE law and compare them with comparative law and jurisprudence. In this regard, I selected the texts of the Jordanian Civil Code, taking into account the impact of this law on the UAE civil law, and to determine the extent of its compatibility or divergence with the position of the UAE legislator regarding its regulation of the principle of good faith in contracts in general, and its regulation of the subject of this study in particular.

Conversely, I chose to compare the UAE Civil Code with the provisions of the Egyptian Civil Code, taking into account that most of the provisions of the Egyptian Civil Code are derived from the French Civil Code, as amended in 2016. I also mentioned some foreign laws and regulations in the margins of some pages, such as the Italian Civil Code, the Principles for the Unification of International Trade Rules, and the UNIDROIT Principles, while reviewing research and academic dissertations directly related to the subject with the aim of benefiting from them.

This study concluded that the principle of good faith in contracts is a matter of public order, and that the basis for the parties' commitment to this principle during the stages preceding contracting is due to the content and nature of this principle. Two important results were also reached regarding the jurisprudential dispute that has arisen in determining the nature of negotiations. The first result relates to the nature of explicit negotiations accompanied by a written agreement regulating the

negotiation process and procedures between the two parties. The nature of these negotiations is considered contractual by virtue of this agreement, and therefore the rules of contractual liability apply to them. The second result concerns negotiations not accompanied by a written and explicit agreement regulating the negotiation process and procedures for a specific contract, which acquire a contractual nature by virtue of what is called an implicit negotiation contract. This may arise between the two parties simply by issuing an offer to negotiate from one party to the other, expressing a serious desire to negotiate with him regarding a specific contract. This offer is coupled with a corresponding acceptance from the latter, or in the case where these negotiations become regular, continue for a reasonable period of time, and are advanced such that the negotiations reach the closest level to concluding a final contract, reflecting the existence of a common and serious intention between the two parties to conduct a contractual regulation for the ongoing negotiations between them. Or in the event that any joint action or deed is issued by the two parties that can be inferred from the existence of an implicit and serious agreement between them to negotiate a contract, in such cases, the nature of negotiations not accompanied by a contractual negotiation is considered contractual, and accordingly, the rules of contractual liability apply. Otherwise, negotiations are considered mere material acts that do not entail any legal effects, and therefore, the rules of tort liability apply.

In this regard, it is clear that the UAE legislator has not kept pace with the developments in some Western legislation, which explicitly impose in their texts the obligation of parties to act in good faith during the negotiation and contract conclusion stages. Furthermore, there is a duality in the application of legal liability provisions to negotiations in the UAE

judiciary. The provisions of tort liability apply to negotiations not accompanied by an explicit negotiation contract, regardless of whether there is an implicit negotiation contract between the two parties. Meanwhile, the provisions of contractual liability apply to negotiations accompanied by an explicit negotiation contract. We also see that everything we have learned regarding the origin and nature of the negotiation phase also applies to the contract conclusion phase, as it is a complementary stage in which what was reached during the negotiation phase is completed. The study recommends some legal provisions that the researcher hopes to include in the Federal Civil Transactions Law to address the legislative shortcomings represented by the failure to regulate the principle of good faith in the stages preceding contracting.

Keywords: Principle of good faith, negotiations, offer, negotiated contract, liability.

أولاً: التعريف بموضوع البحث

تنقسم مراحل تكوين العقد النهائي إلى مرحلتين مختلفتين عن بعضهما البعض، الأولى: هي مرحلة المفاوضات، أما الثانية: فهي مرحلة إبرام العقد. وتجدر الإشارة هنا بأنه من غير الضروري أن يمر العقد أثناء تكوينه، بهاتين المرحلتين معاً. حيث يتوقف تحديد هذا الأمر على طبيعة العقد النهائي، فإذا كان من العقود البسيطة المألوفة في حياتنا، كعقود الاستهلاك اليومية، فلا يتطلب عادةً لانعقاده دخول الأطراف في مفاوضات بشأنه، ويكفي لإتمام انعقاده أن يمر العقد بمرحلة إبرام العقد فقط. وعلى عكس ذلك، فيما لو كان العقد النهائي من العقود المعقدة، والمركبة¹، التي تعد من نتاج التطور المتسارع في كافة المجالات الحيوية في الوقت الراهن، "مثل: عقود نقل التكنولوجيا، وعقود التنقيب عن المعادن، وعقود التوريدات الضخمة، وعقود الإنشاءات الهندسية"² وغيرها. فهذا النوع من العقود من المستحيل انعقاده بشكل فوري، ويتطلب لانعقاده الدخول في مفاوضات جديدة، ومكثفة، قد تستغرق فترة من الزمن، الأمر الذي يستلزم أن يمر العقد خلال فترة تكوينه بهاتين المرحلتين³.

1 "وهي عقود تنصب على عمليات ذات تعقيدات فنية مركبة وتبرم بين شركات عملاقة وضخمة والتي يمتد تنفيذها لفترة زمنية طويلة". نقلاً عن أبحار حامد حبش علي، المسؤولية المدنية عن قطع المفاوضات العقدية، رسالة ماجستير، جامعة الاسراء الخاصة -كلية الحقوق، الأردن، 2015، ص 13.

2 نقلاً عن هدى بن يوب، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية-قسم الحقوق، الجزائر، 2013، ص 113.

3 عبد العزيز المرسي حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدية: "دراسة مقارنة"، المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، الناشر: جامعة المنوفية-كلية الحقوق، مصر، مجلة محكمة، مج 10، ع 20، 2001، ص 207.

ونتناول في هذا البحث دراسة ماهية هذه المراحل، وأساس التزام الأطراف بمبدأ حسن النية خلالها، وطبيعة المسؤولية القانونية في هذه المراحل، وعلى أساس ذلك يتم تحديد طبيعة مسؤولية الإخلال بهذا المبدأ خلال هذه المراحل-موضوع هذه الدراسة.

ثانياً: أهمية البحث وأهدافه

1. من الناحية النظرية: تُمكننا هذه الدراسة من معرفة طبيعة المراحل السابقة على التعاقد، الأمر الذي يُسهل علينا معرفة طبيعة قواعد المسؤولية القانونية المطبقة على الطرف المخل بمبدأ حسن النية خلال هذه المراحل. كما تُمكننا هذه الدراسة أيضاً من معرفة التوجه التشريعي والقضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الخصوص؛ ومعرفة مدى تماشي هذا التوجه مع التطور الحاصل في الفقه والقانون المقارن في هذا الشأن من عدمه؟

2. من الناحية التطبيقية: قد يساهم تحديث نصوص قانون المعاملات المدنية الاتحادي بدولة الإمارات وفقاً لمخرجات هذه الدراسة في معالجة القصور التشريعي في القانون المذكور المتعلق بتنظيم مبدأ حسن النية خلال المراحل السابقة على التعاقد، كما أن من شأن ذلك أن يعزز دور مبدأ حسن النية في حماية الطرف حسن النية المتضرر من تصرفات الطرف الآخر أثناء تعامله معه خلال هذه المراحل، الأمر الذي يساهم في إعادة التوازن العقدي خلال هذه المراحل، ومن ثم تحقيق العدالة المنشودة.

ثالثاً: إشكالية البحث

تتمحور إشكالية البحث الأساسية في تحديد طبيعة المسؤولية الناجمة عن الإخلال بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد، وللتمكن من الوصول إلى حل لهذه الإشكالية، فإنه ينبغي الإجابة على بعض التساؤلات المثارة في هذا الشأن وفقاً للآتي:

1. ما هو الفارق بين مفهوم مرحلة المفاوضات ومرحلة إبرام العقد؟ وما هو الحد الفاصل بينها؟
2. وما هو أساس التزام الأطراف بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد؟
3. وما هو الفارق بين المفاوضات القائمة على عقد تفاوض صريح والمفاوضات القائمة على عقد تفاوض ضمني؟ وما هي طبيعة كل منهما؟
4. وما هو عقد التفاوض وأنواعه؟ وهل له تأثير على طبيعة هذه المراحل؟
5. وما هو نوع قواعد المسؤولية التي يفترض تطبيقها على الطرف المخل بمبدأ حسن النية أثناء تعامله مع الطرف الآخر خلال مرحلتي المفاوضات وإبرام العقد؟ وهل نظم المشرع الإماراتي هذه المسألة؟
6. وهل اعترف القضاء الإماراتي بمرحلة المفاوضات ورتب عليها آثاراً قانونية؟

رابعاً: منهج البحث

تم الاعتماد في هذا البحث على المناهج الآتية:

1. المنهج التحليلي، لتحليل موقف المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي من تنظيم المراحل السابقة على التعاقد من عدمه؛ ومعرفة مدى كفاية النصوص في تنظيم مبدأ حسن النية خلال هذه المراحل من عدمه؛ ومدى الحاجة إلى تعديل بعض النصوص؛ أو استحداث نصوص جديدة في القانون المذكور في هذا الشأن من عدمه.
2. المنهج المقارن، لمعرفة مدى توافق المشرع المدني الإماراتي مع موقف القانون المقارن، وفي هذا الصدد اخترت المقارنة مع القانونين المصري والأردني وفقاً لما بينته من أسباب في ملخص الدراسة، بالإضافة إلى بحث موقف القانون المدني الفرنسي وفقاً لتعديل سنة 2016؛ وبعض القوانين والأنظمة الأجنبية ذات الصلة

بموضوع الدراسة للاستفادة منها، مع اطلاعنا على موقف الفقه المقارن بهذا الخصوص.

3. المنهج التطبيقي، لمعرفة موقف القضاء الإماراتي والقضاء في مصر والأردن من تحديد طبيعة مسؤولية الإخلال بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد، وهل يوجد تشابه أم اختلاف في مواقف كلاً منها، مع الاستشهاد ببعض السوابق القضائية للقضاء المدني الفرنسي ذات الصلة بموضوع الدراسة للاستفادة منها.

خامساً: خطة البحث

بقصد التوصل لإجابة على إشكالية البحث الموضحة أعلاه، تم تقسيم خطة البحث على النحو الآتي:

- المبحث الأول: ماهية المراحل السابقة على التعاقد
 - المطلب الأول: مفهوم المراحل السابقة على التعاقد
 - المطلب الثاني: أساس التزام الأطراف بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد
- المبحث الثاني: طبيعة المسؤولية في المراحل السابقة على التعاقد
 - المطلب الأول: المسؤولية القانونية المطبقة على المفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني
 - المطلب الثاني: المسؤولية القانونية المطبقة على المفاوضات بموجب عقد تفاوض صريح

المبحث الأول

ماهية المراحل السابقة على التعاقد

لا شك، بأن معرفة ماهية المراحل السابقة على التعاقد؛ يُسهل علينا دراسة كل مرحلة على حدة؛ ويستتبع ذلك تحديد أساس التزام الأطراف بمبدأ حسن النية خلالها، الأمر الذي من شأنه أن يساعدنا على تحديد طبيعة هذه المراحل من جهة؛ بالإضافة إلى تحديد طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإخلال بهذا المبدأ خلال هذه المراحل من جهة أخرى.

المطلب الأول

مفهوم المراحل السابقة على التعاقد

تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين، نتحدث في الأول عن مفهوم مرحلة المفاوضات، بينما نتحدث في الثاني عن مفهوم انتهاء مرحلة المفاوضات وإبرام العقد النهائي.

الفرع الأول

مفهوم مرحلة المفاوضات

توصف مرحلة المفاوضات بأنها مرحلة استكشافية للأطراف الراغبة في التعاقد، حيث يتعرف كل طرف خلال هذه المرحلة على شروط ومتطلبات الطرف الآخر، وعلى المواصفات الخاصة بمحل المفاوضة، وعلى مشروع العقد المستقبلي، من خلال تبادل وجهات النظر؛ والمقترحات، والآراء؛ والدراسات ذات الصلة بموضوع المفاوضة؛ ليصبح كل طرف على بينه من شروط وأحكام العقد المراد إبرامه، الأمر الذي يجعله قادراً على تقييم موقفه من المفاوضة، وما إذا كان يرغب في العدول أو الاستمرار فيها من عدمه. كما توصف أيضاً بأنها مرحلة تأسيسية للعقد النهائي المراد إبرامه، يتم

خلالها تحديد المعالم الرئيسية لهذا العقد¹.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن للمفاوضات تأثير كبير على مستقبل العقد النهائي، حيث يتم خلالها تحديد أغلب الالتزامات والحقوق المراد تضمينها في العقد المراد إبرامه، مما يضمن للطرفين المحافظة على التوازن العقدي في هذا الجانب خلال فترة تنفيذ هذا العقد. كما أن لهذه الفترة تأثير كبير على صياغة العقد النهائي، فكلما كانت المفاوضات ناجحة، كلما أدى ذلك إلى صياغة مشروع العقد النهائي بصورة محكمة، مما يترتب عليه التقليل من حدوث نزاعات مستقبلية بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد. هذا إلى جانب دور المفاوضات في تفسير بنود وأحكام العقد النهائي، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك؛ فالقاضي قد يعتمد في تفسيره على مجريات المفاوضات، للكشف عن النية الحقيقية المشتركة للأطراف. ولا ننسى أيضاً دور المفاوضات المهم في تكميل العقد النهائي، وذلك في الحالة التي يحيل فيها الأطراف إلى المفاوضات لتنظيم مسألة معينة للعقد، كتحديد ثمن المبيع، أو محل العقد وغيرها من الأمور، ففي هذه الحالة تعتبر المفاوضات جزءاً لا يتجزأ من العقد النهائي. بالإضافة إلى دورها الهام في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعقود ذات الطبيعة الدولية؛ وكذلك دورها في تسوية النزاعات المحتملة، التي قد تثور بين الطرفين أثناء تفاوضهم، فيما لو اتفق الأطراف على أحكام معينة تنظم هذه النزاعات².

1 ورد في الفقه العديد من التعريفات للمفاوضات، نذكر منها التعريف الآتي: "بأنها المناقشة المشتركة بين طرفين متقابلين بصدد عناصر عقد مستقبلي"، كما جاء في تعريف آخر لها بأنها: "تبادل وجهات النظر حول موضوع العقد وشروطه ومناقشتها، وتعبير المفاوضين عن موقفهم من العروض والعروض المقابلة تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي". مشار لهذين التعريفين لدى خالد صقر أبو زهرة، التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في فلسطين: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت- كلية الدراسات العليا، فلسطين، 2021، ص 12.

2 رعد أحمد عبد ربه اللوزي، التنظيم القانوني لمراحل المفاوضات العقدية في القانون الأردني، رسالة
==

وبصدد تحديد نطاق فترة المفاوضات، يمكن القول، بأن هذه الفترة تبدأ منذ لحظة قبول الطرف الآخر للإيجاب بالتفاوض الصادر عن الطرف الراغب في التفاوض معه بشأن عقد ما¹. مع الجدير بالملاحظة هنا، بأنه يتعين لاعتبار ما يقوم به الطرفان من مناقشات؛ ومباحثات؛ وإجراءات وغيرها ضمن دائرة المفاوضات، أن تصدر هذه الأعمال بناءً على تبادل مشترك بين الطرفين؛ بنية الوصول إلى اتفاق حول العقد المراد إبرامه بينهما. وترتيباً على ذلك؛ فإنه يستبعد من نطاق المفاوضات؛ المناقشات التي تحدث بين الطرفين قبل التعاقد، بقصد الاستفسار أو السؤال عن أمر معين، وكذلك، المناقشات التي تصدر من طرف واحد، كالحوارات التي تحدث بين الطرفين ومستشاريه. وأيضاً، المناقشات التي تتم بين أشخاص متعددين؛ لكنهم يمثلون جانب واحد في المفاوضات، كالمناقشات التي تحدث بين شركتين للتوصل إلى تفاهم بخصوص تمثيلهم كطرف واحد في المفاوضات الجارية مع الطرف الآخر، فهذا النوع

==

دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية-كلية الدراسات العليا، الأردن، 2016، صص 29-34 و19؛
 ايناس مكي عبد نصار، التفاوض الالكتروني: دراسة مقارنة في ظل بعض التشريعات العربية
 المعاصرة، المصدر: مجلة جامعة بابل-العلوم الإنسانية، الناشر: جامعة بابل، العراق، مجلة محكمة،
 مج 21، ع 3، 2013، ص ص 951-952.

1 قد يصدر الإيجاب بالتفاوض بشكل صريح وذلك في الحالتين الآتيتين: (1) إذا وجه الإيجاب إلى شخص معين دون الدعوة إلى المناقشة وهو أسلوب التعاقد المباشر. (2) إذا وجه الإيجاب إلى الجمهور مع الدعوة إلى المناقشة وهو أسلوب التعاقد بطريق المناقصة؛ كما قد يصدر بشكل ضمني إذا اتخذ إحدى الصورتين: (1) إذا لم يتضمن الإيجاب العناصر الجوهرية للعقد المستقبلي المراد إبرامه؛ كمن يعرض سيارته أو منزله للبيع أو الإيجار دون ذكر الثمن. (2) إذا اقترن الإيجاب بتحفظ مطلق، وهو تحفظ تحكي يعطي للموجب امكانية الموافقة أو عدم الموافقة على إبرام العقد مع شخص معين، مما يفقده صفته كإيجاب بالتعاقد، ويحوّله إلى إيجاب ضمني بالتفاوض. للمزيد من التفصيل حول الإيجاب بالتفاوض وأنواعه انظر: عبدالعزیز المرسي حمود، مرجع سابق، ص ص 222-224؛ أنظر أيضاً رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص ص 35-42.

من التفاوض لا يرتب أية التزامات على الطرف الآخر، نظراً لعدم ارتباطها بمحل التفاوض الأصلي، ولصدورها من طرف واحد، إلا إذا اتفق أطراف التفاوض على اعتبارها جزءاً من مفاوضات العقد المراد إبرامه¹.

كما يستبعد من نطاق فترة المفاوضات أيضاً، تلك المناقشات التي تجري بين الطرفين بعد انعقاد العقد النهائي، حيث تعتبر هذه المفاوضات أثراً من آثار العقد النهائي، ويطبق بشأنها الأحكام المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، بخلاف طبيعة المفاوضات السابقة على التعاقد²، التي سنحاول تحديدها في المبحث الثاني من هذا البحث بالتزامن مع دراسة طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإخلال بمبدأ حسن النية خلال المراحل السابقة على التعاقد، نظراً لوجود ارتباط وثيق بين هذين الموضوعين، وتنادياً للتكرار.

هذا، وتنتهي فترة المفاوضات منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها مرحلة إبرام العقد وفقاً لما سوف نبينه في الفرع التالي.

1 محمد أحمد محمود العكام، العدول عن إبرام العقد في مرحلة التفاوض وأثره القانوني، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية-كلية الدراسات العليا، الأردن، 2015، ص ص 11-13؛ شرف علي خالد بعيورات، آثار الإخلال بمبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات العقدية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك-كلية القانون، الأردن، 2018، ص ص 68-69.

2 محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 8؛ وفي هذا الصدد، يعبر اتجاه في الفقه للتفريق بين التفاوض السابق واللاحق على التعاقد بالقول: "فالالتزام بالتفاوض في مرحلة التنفيذ يدخل إلى حد كبير في إطار العدالة، بينما التفاوض في مرحلة الانعقاد يدخل في دائرة القانون حيث يجب أن يسود مبدأ حسن النية بما يحققه من عدالة طبقاً لما تقرره النصوص القانونية". نقلاً عن هدى بن يوب، مرجع سابق، ص 113.

الفرع الثاني

مفهوم انتهاء مرحلة المفاوضات وإبرام العقد النهائي

مرحلة إبرام العقد النهائي هي تلك " المرحلة التي يتم فيها انعقاد العقد نهائياً وذلك عن طريق تبادل إيجاب وقبول متطابقين دون الخوض في نقاش حوله"¹ وقد اختلف الفقه² في تحديد نطاق هذه المرحلة إلى رأيين، الأول يوسع من نطاق المفاوضات، ويعتبرها كل الفترة قبل العقدية، بحيث لا تنتهي إلا منذ اللحظة التي ينعقد فيها العقد نهائياً، وهو بذلك يجعل مرحلة إبرام العقد جزءاً من مرحلة المفاوضات.

بينما ذهب الرأي الثاني - ونؤيده في ذلك- إلى التفريق بين مرحلة إبرام العقد ومرحلة المفاوضات، من خلال تحديد الحد الفاصل بين هاتين المرحلتين من الناحية الموضوعية. وبموجب هذا الرأي، تنتهي فترة المفاوضات منذ اللحظة التي يصدر فيها إيجاب بالتعاقد³، وبمجرد صدوره ينتقل الطرفان من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة إبرام العقد النهائي. فالإيجاب بالتعاقد هو عرض يعبر به الشخص بوجه جازم، وقطعي عن إرادته في إبرام عقد معين، ويتضمن جميع المسائل الجوهرية الكافية لانعقاد العقد النهائي، فيما لو اقترن هذا الإيجاب بقبول مطابق. أما الإيجاب

1 عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 207.

2 ذات المرجع، ص ص 209-210.

3 غالباً ما يتشارك المتفاوضان في تشكيل الإيجاب بالتعاقد في العقود التي تحتاج لانعقادها الدخول في مفاوضات، ويحدث ذلك عندما لا يلقي الإيجاب الأول قبولاً ولا رفضاً من الطرف الثاني، بل يصادفه اقتراح مضاد يشمل تعديلاً لهذا الإيجاب، وقد يتكرر ذلك، عندما يقدم الموجب (صاحب الإيجاب الأول) اقتراحاً مضاداً بتعديل الإيجاب الثاني، وهكذا يتبادل الطرفان خلال فترة إبرام العقد الاقتراحات المضادة، إلى أن يصل كل منهما إلى قناعة مشتركة = بخصوص الإيجاب الذي يتوافق مع مصلحة كل طرف. لذلك، قيل عن الإيجاب بالتعاقد الذي تسبقه فترة مفاوضات بأنه: " إيجاب مفصل على القياس". عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص ص 210-211؛ انظر أيضاً أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 19.

بالتفاوض فهو عبارة عن عرض يعبر به الشخص عن إرادته العازمة على التفاوض، دون أن يعلن فيه عن إرادته الباتة والنهائية في إبرام العقد النهائي المراد إبرامه، أو أن يتضمن المسائل الجوهرية لهذا العقد¹. ونخلص من هذين التعريفين، بأن الإيجاب سواء كان يهدف لإبرام عقد نهائي أو تفاوضي فإنه سيؤدي لإبرام عقد بمجرد أن يكون باتاً وجازماً²؛ ومحددًا تحديداً كافياً³؛ واقترن به قبول مطابق من الطرف الآخر.

1 عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، صص 220 و 212؛ أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 17؛ أنظر أيضاً لدى محمد أحمد المبيضين، التزامات المفاوض في عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة عمادة الدراسات العليا، الأردن، 2018، صص 20-23؛ محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، صص 22-26 و 19-17.

2 هذا، ويعتبر الإيجاب بالتعاقد باتاً إذا صدر بنية حاسمة تدل على إرادة الموجب النهائية في إبرام العقد، بحيث ينعقد بمجرد قبول الطرف الآخر دون وجود قيد أو تحفظ، من شأنه أن يعلق إبرام العقد على أمر آخر غير القبول. فالأصل أن يكون الإيجاب مجرداً من أي تحفظ، ومع ذلك فإنه إذا تحفظ الموجب بشكل نسبي على إيجابه، بأن قيد إبرام العقد على حدوث ظروف موضوعية لا يد للموجب فيها، كتعليق التعاقد على عدم نفاذ السلعة موضوع الإيجاب، فهذا النوع من التحفظ وإن كان يقيد الإيجاب بالتعاقد إلا أنه لا يلغي صفته كإيجاب، فالعقد يتم بمجرد اقتران هذا الإيجاب بقبول من الطرف الآخر، إلا أنه يكون مقيداً بهذا التحفظ، بخلاف الوضع، إذا كان الإيجاب مقترناً بتحفظ مطلق، وهو التحفظ الذي يجعل إبرام العقد من عدمه راجع إلى الموجب وحده، فهذا التحفظ التحكيمي يلغي صفة الإيجاب بالتعاقد ويحوّله إلى إيجاب بالتفاوض. لمزيد من التفصيل في هذه الجزئية انظر عبدالعزيز المرسي حمود، مرجع سابق، صص 215-212؛ انظر أيضاً خالد صقر أبو زهرة، مرجع سابق، ص ص 20-15؛ وكذلك أبحار حامد حبش، مرجع سابق، ص ص 24-21.

3 يقتضي هذا الشرط أن يتضمن الإيجاب تحديداً لطبيعة العقد المراد إبرامه ولجميع عناصره الجوهرية، سواء كانت هذه العناصر موضوعية و"هي التي تقتضيها طبيعة العقد ذاته وبدونها يتعذر معرفة نوع العقد المراد إبرامه"، أو كانت هذه العناصر شخصية وهي "عناصر تعتبر وفقاً لطبيعة العقد ثانوية في الأصل ولكنها تتحول إلى عناصر جوهرية لما اكتسبته من أهمية ذاتية في نظر أحد الطرفين أو كليهما"، ويترك أمر تحديدها للأطراف أنفسهم. عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص ص 220-216؛ أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص ص 27-24.

والجدير بالتنويه هنا، بأن مسألة التفريق بين الإيجاب بالتعاقد والإيجاب بالتفاوض، تعتبر مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضي الموضوع، دون رقابة عليه من محكمة القانون، طالما كان استخلاصه سائغاً ومتوافقاً مع حكم القانون¹.

كما تجدر الإشارة أيضاً، بأن التباين بين مرحلتي المفاوضات وإبرام العقد؛ لا يقف عند حد النطاق الموضوعي وهو صدور إيجاب بالتعاقد بمعناه القانوني؛ بل ينبغي أيضاً تحديد النطاق الزمني الذي يوضح الاختلاف بين هاتين المرحلتين. فالمفاوضات تعتبر أول فترة من فترات المراحل قبل العقدية، وبالتالي فهي دائماً تسبق مرحلة إبرام العقد. كما أن فترة المفاوضات غالباً ما تستغرق وقتاً أطول من فترة إبرام العقد، لما تتطلبه من عقد اجتماعات، ومناقشات، وتبادل الدراسات المتخصصة، وصولاً نحو إبرام العقد المنشود. بخلاف مرحلة إبرام العقد التي عادةً لا تستغرق سوى فترة زمنية قصيرة، على اعتبار أن الأطراف قد توصلوا إلى تفاهم مشترك فيما بينهم خلال فترة المفاوضات حول بنود وشروط العقد النهائي المراد إبرامه، بحيث لم يتبق أمامهم سوى تبادل إيجاب بالتعاقد، وصدور قبول مطابق له، لانعقاد هذا العقد².

وبعد توضيح أوجه الاختلاف بين مرحلة المفاوضات ومرحلة إبرام العقد النهائي، ننتقل للمطلب التالي لتحديد أساس التزام الأطراف بمبدأ حسن النية خلال هذه المراحل.

1 لى محمد أحمد المبيضين، مرجع سابق، ص 23.

2 خالد صقر أبو زهرة، مرجع سابق، ص ص 20-21.

المطلب الثاني أساس التزام الأطراف بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد

نخصص هذا المطلب للتعرف على موقف التشريعات من تنظيم مبدأ حسن النية في مرحلتها المفاوضات وإبرام العقد، بالإضافة إلى معرفة الأقوال التي قيلت في الفقه بخصوص تحديد أساس التزام الأطراف بهذا المبدأ خلال هذه المراحل.

الفرع الأول موقف التشريعات

لقد انقسمت التشريعات الوضعية في اعترافها بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول منها فهو يعترف بدور هذا المبدأ، وتأثيره في هذه المراحل، إلا أنه لم ينص عليه بشكل صريح، ويعلق البعض بهذا الخصوص¹ بالقول بأن أغلب التشريعات المدنية العربية، وإن لم تكن جميعها، قد أخذت بالمبدأ العام للتفاوض بحسن نية، لكنها لم تنص عليه صراحةً في نصوصها. ونرى أن هذا الأمر يعد نقصاً تشريعياً يشوب أغلب التشريعات المدنية في هذا الشأن؛

1 هدى بن يوب، مرجع سابق، ص 114؛ "وفي هذا المعنى يقول الدكتور محفوظ لعشب: يجب أن لا يقتصر مبدأ حسن النية على مرحلة تنفيذ العقد فقط وإنما يجب الأخذ به قبل ذلك في أي مرحلة لاسيما عند وضع الشروط التعاقدية.. ويجب أن تصاغ تلك الشروط صياغة فنية واضحة تدل على حسن نية واضعها لتكون بعيدة عن التأويل وقابلة للتحليل المنطقي" نقلاً عن هائل حزام العامري، مبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني اليمني وبعض القوانين الأخرى: دراسة تحليلية مقارنة، المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية، الناشر: قارة وليد، الجزائر، مجلة محكمة، ع 18، 2018، ص 57؛ مشار إليه أيضاً لدى توحيد محمد يوسف السيد، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد: دراسة قانونية، المصدر: مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية، الناشر: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البليدة 2، السودان، مجلة محكمة، ع 5، 2021، ص 160.

كقانون المعاملات المدنية الاتحادي بدولة الإمارات¹، والقانونين المدني المصري² والأردني³؛ يتعين عليها تداركه بالنص عليه صراحةً في نصوصها في هذه المراحل.

أما القسم الثاني من التشريعات، وأغلبها تشريعات غربية؛ فقد نصت صراحةً في نصوصها على التزام الأطراف بمبدأ حسن النية خلال فترة التفاوض⁴، نذكر منها على

1 قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1985، نشر بتاريخ 21 مارس 1985 في الجريدة الرسمية، العدد (158)، والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 1/1987 بتاريخ 14/2/1987 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 27/09/2020 بتاريخ 30/09/2020.

2 القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الصادر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 هـ (16 يوليو سنة 1948) وفقاً لأحدث تعديلاته له- نسخة من إعداد وزارة المالية، القطاع: شئون اجتماعية وثقافية- الأحوال الشخصية، نوع الوثيقة: قوانين ولوائح-قوانين، منشورات قانونية- أرشيف رقمي، تاريخ الاطلاع على شبكة الانترنت: 17/11/2024، على الرابط:

<https://manshurat.org/node/72413>.

3 القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2645 على الصفحة 2 بتاريخ 1/8/1976 والساري بتاريخ 1/1/1977 وتعديلاته، منقح ومحدث حتى سنة 2024، موقع حُماة الحق للمحاماة، تاريخ الاطلاع على شبكة الانترنت 17/11/2024، على الرابط:

<https://jordan-lawyer.com/2010/07/11/jordan-civil-law-with-all-amendments/>.

4 ومن أمثلة هذه التشريعات نذكر القانون المدني الإيطالي الذي أوجب صراحةً هذا المبدأ أثناء التفاوض بموجب المادة (1337) منه: " يلتزم الأطراف أثناء المفاوضات وإبرام العقد بالتعامل بما يتفق وحسن النية" انظر مبارك محمد آل فطيح، دور القاضي في تطبيق مبدأ حسن النية في العقد، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا، الأردن، 2010، هامش ص 69؛ ومحمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 38؛ ورعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 47؛ كما نجد نفس التوجه أيضاً في القانون المدني اليوناني في المادة (197) منه؛ وفي قانون العقد اليوغسلافي في المواد (30) و(17) نقلاً عن حمدي محمود بارود، المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها: مبدأ حسن النية ومقتضياته-دراسة تأصيلية تحليلية، المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا، فلسطين، مجلة محكمة، مج 16، ع 1، 2008، ص 843؛ ومن

سبيل المثال، القانون المدني الفرنسي وفقاً لتعديل سنة 2016، حيث نص المشرع الفرنسي صراحةً على هذا المبدأ في المادة (1104) منه: " يجب التفاوض على العقود، إبرامها وتنفيذها بحسن نية. يعتبر هذا الحكم من النظام العام". وبموجب هذا النص اعترف المشرع المدني الفرنسي صراحةً لأول مرة بمرحلة المفاوضات كمرحلة مستقلة بحد ذاتها عن المراحل العقدية الأخرى، كما رتب عليها أثراً قانونياً، من خلال إلزام الأطراف بحسن النية أثناء التفاوض، واعتبر هذا الالتزام متعلقاً بالنظام العام، مما يعني ذلك، بأن المشرع الفرنسي وسع من نطاق تطبيق مبدأ حسن النية ليشمل جميع

==

التشريعات الغربية التي اعترفت صراحةً بهذا المبدأ خلال فترة المفاوضات القانون المدني الألماني، والقانون المدني الياباني. انظر نادية زوفاغ، مبدأ حسن النية في التفاوض الالكتروني في مجال عقود التجارة الدولية، المصدر: المحلل القانوني، الناشر: جامعة أكلي محند اولحاج بالبوية- مخبر الدولة والإجرام المنظم، الجزائر، مجلة محكمة، مج 2، ع2، 2020، ص 125؛ كما نصت مبادئ توحيد قواعد التجارة الدولية صراحةً على مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات في المادة (5/2) منها: " - يتمتع كل طرف بحرية التفاوض ولا يعد مسؤولاً عن عدم التوصل إلى اتفاق. ٢ - إن الطرف الذي يقوم بالتفاوض أو يقوم بقطع مفاوضاته بسوء نية، يكون مسئولاً عن الخسائر التي يتكبدها الطرف الثاني. 3- إن الدخول في مفاوضات أو الاستمرار فيها من قبل الطرف الذي لا ينوي التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر يعد تصرفاً مقروناً بسوء نية" مبارك محمد آل فطيح، مرجع سابق، ص 69؛ نادية زوفاغ، مرجع سابق، ص 126؛ كما ورد ذات الحكم في المادة (2-1) 15 من مبادئ اليونيدروا سوء النية في مرحلة المفاوضات حيث جاء فيها: " (التفاوض بسوء نية)

- 1) للأطراف حرية التفاوض ولا يسألون عند عدم التوصل إلى اتفاق.
- 2) مع ذلك، يسأل الطرف الذي يتفاوض أو يقطع المفاوضات، بسوء نية، عما لحق بالطرف الآخر من أضرار.
- 3) ويعد من قبيل سوء النية، بوجه خاص، دخول طرف في التفاوض أو استمراره فيه بالرغم من نيته عدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر."

مشار لهذا النص لدى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التركي، أثر مبدأ حسن النية في العقود التجارية، المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية، الناشر: عبد الفتاح محمود ادريس، مصر، مجلة محكمة، مج 6، ع 63، 2017، ص 77.

مراحل العقد هذا من جهة، كما أنه من جهة أخرى فرض بقوة القانون على الأطراف التزاماً قانونياً باحترام ما يفرضه هذا المبدأ في أي مرحلة وصل إليها الأطراف، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، كما لا يجوز الاتفاق على إعفاء أحد الأطراف أو كلاهما من التقيد بأحكامه¹. فضلاً عن نص المادة (1112) من نفس القانون الذي ألزم صراحةً الأطراف بمراعاة مقتضيات حسن النية عند اقتراح أو سير أو قطع المفاوضات قبل التعاقدية².

وعلى خلاف ما تقدم، نجد بعض التشريعات الغربية تستبعد أعمال مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض، كالنظام الانجلوساكسوني³ الذي لا يعترف بفكرة حسن

1 للتفصيل بهذا الخصوص انظر أم كلثوم صبيح محمد وأسماء صبر علوان، الالتزام بالإعلام في ضوء تعديلات القانون الفرنسي بموجب مرسوم 10 أكتوبر 2016، المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانية والاجتماع، الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية، مجلة محكمة، ع 19، 2018، ص ص 88-87؛ ولى محمد أحمد المبيضين، مرجع سابق، ص ص 69-68.

2 نصت المادة (1112) من القانون المدني الفرنسي المشار إليه على: "يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها حراً. يجب لزاماً أن تراعي هذه المسائل مقتضيات حسن النية. تعويض الضرر الناجم عن الخطأ الحاصل خلال المفاوضات لا يشمل خسارة المزايا التي كانت منتظرة من العقد الذي لم يتم إبرامه". ترجمة محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية- المواد 1100 إلى 1231-7 من القانون المدني الفرنسي، منشورات الحلبي، بيروت- لبنان، 2018، ص 34.

3 وهو النظام المطبق في بريطانيا وأمريكا وغيرها من دول القانون العام. ومن الأمور التي ساهمت في ابتعاد التشريع الإنجليزي عن تطبيق أحكام مبدأ حسن النية في التفاوض: اشتراط القضاء الإنجليزي - باعتباره المصدر الرسمي من مصادر القانون المدني الإنجليزي- توافر عنصر اليقين في الالتزام العقدي. بمعنى آخر يجب أن يكون الالتزام العقدي متحققاً ومؤكداً، وهذا ما يخالف بالتأكيد طبيعة الالتزام التفاوضي، الذي يقوم على عنصر الاحتمالية والمخاطرة، وليس على عنصر اليقين. وذات التوجه، نجده في القانون المدني الأمريكي، الذي اعتبر التفاوض مجرد عمل مادي قائم على المخاطرة والاحتمالية. لذلك، لا يترتب عليه أية التزامات على الطرفين، وبالتالي يجب على المتفاوض تحمل مسؤولية تفاوضه، إلا في حالي الغش والتدليس، ففي مثل هذه الحالات فقط، يساءل المتفاوض ==

النية في العقود بصفة عامة، وفي التفاوض بصفة خاصة، ويرجع سبب ذلك إلى تقديس هذا النظام لمبدأ الحرية الفردية، الذي يمنح للفرد مطلق الحرية في التعاقد من عدمه، وفي الدخول في التفاوض أو الانسحاب منه في أي وقت، دون أن يتحمل أية مسؤولية تجاه الطرف الآخر، طالما تبين له بأن العقد محل المفاوضة لا يحقق مصالحه الشخصية. ومما يؤكد هذا الموقف أيضاً، تبني هذا النظام لفكرة المقابل أو الفائدة أو الاعتبار، وبموجبها يعتبر العقد مجرد صفقة أو مصلحة، ينبغي أن يستفيد منها الطرفين، فإذا انعدمت الفائدة منه، انعدم معها العقد. لذلك، يُسمح للفرد بتغليب مصالحه الشخصية عند التعاقد باستخدام جميع الوسائل المتاحة ما عدا الوسائل الاحتيالية.

وبعد استعراض الأساس القانوني لالتزام الأطراف بمبدأ حسن النية خلال المراحل السابقة على التعاقد في بعض التشريعات، ننتقل إلى الفرع الثاني للتعرف على رأي الفقه في هذه المسألة.

الفرع الثاني موقف الفقه

لا خلاف في الفقه المقارن حول وجوب تطبيق مبدأ حسن النية خلال المراحل السابقة على التعاقد- بغض النظر عن اختلافه في تحديد أساس تطبيقه- إدراكاً منه

==

مرتكب هذا الفعل طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. وقد استحدثت كلاً من القانون والقضاء المدني البريطاني والأمريكي، للاستعاضة عن تطبيق مبدأ حسن النية في التفاوض؛ بعض القواعد والمفاهيم والآليات، على سبيل المثال لا الحصر: حظر وسائل الغش والاحتيال، والإنراء بلا سبب، والتدليس، والوعد المحدد، والمنافسة غير المشروعة. فضلاً عن اعتراف كلاً منهما في الآونة الأخيرة باتفاق التفاوض في حال ورد صريحاً في خطاب النوايا. للمزيد في هذه الجزئية انظر لى محمد أحمد المبيضين، مرجع سابق، ص 79-73؛ نادية زوفاغ، مرجع سابق، هامش ص 126؛ هدى بن يوب، مرجع سابق، هامش ص 114؛ أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 30.

لأهميته في تنظيم التعامل بين الأفراد خلال هذه المراحل. ونبين فيما يلي الآراء التي قيلت في هذا الصدد.

الغصن الأول القول بالزامية مبدأ حسن النية كونه مستتباً من قواعد الأخلاق

يرى جانب من الفقه¹، بأن سبب إلزام الأطراف بمبدأ حسن النية خلال فترة المفاوضات راجع إلى مضمون هذا المبدأ، وما يحتويه من مقتضيات موضوعية؛ كونه مستتباً من قواعد الأخلاق والآداب، والتي وإن كانت غير إلزامية من حيث الأصل؛ إلا أنها تعكس قيم وأخلاق المجتمع من جهة، كما أنها تضيف أثراً تهذيبياً على التصرف ذاته من جهة أخرى، الأمر الذي ينبغي معه احترامها؛ وعدم الخروج عنها أثناء المفاوضات، وإن لم يوجد نص قانوني صريح بشأنها. كما أن لقواعد الأخلاق والآداب تأثير واضح على مجرى المفاوضات، فالتفاوض الأخلاقي غالباً ما يؤدي إلى إنجاح المفاوضات، بعكس التفاوض غير الأخلاقي فهو دائماً ما يؤدي إلى الفشل والخسارة لا غير. لذلك، نجد من يقول² بأن مبدأ حسن النية كافٍ وحده لتنظيم المفاوضات، دون حاجة إلى وجود تنظيم تشريعي يفرض تطبيقه على الأطراف.

1 رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، صص 64 و 56.

2 يصف أصحاب هذا الاتجاه المفاوضات بأنها نظام قانوني خاص، فهم يرون بأنه ينبغي تحرير مفهوم المفاوضات عن المفهوم التقليدي الذي يُخضع المفاوضات للمبادئ الحاكمة للعقد، كمبدأ سلطان الإرادة، وحرية التعاقد، حيث أصبح المفهوم الحديث للمفاوضات يفرض على الأطراف بعض القيود والاعتبارات التي من شأنها أن تقيد من حرية الإرادة في التعاقد، كقواعد النظام العام والآداب العامة، وحسن النية، وعدم الإضرار بالغير. انظر أبحار حامد حبش، مرجع سابق، ص 48.

الفصل الثاني

القول بالزامية مبدأ حسن النية بنص القانون أو العقد

ذهب جانب آخر من الفقه¹ إلى أن سبب التزام الأطراف بمبدأ حسن النية أثناء التفاوض راجع إلى القانون نفسه² كونه يفرض على أطراف التعاقد تنفيذ العقد بحسن نية، الأمر الذي يستدل منه وجوب مراعاة هذا المبدأ أثناء تكوين العقد. والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية، إذ كيف يفرض على الأطراف تنفيذ عقد بحسن نية، وهو في الأساس قد نشأ وتكون بطريقة تخالف حسن النية؟ في حين يرى آخرون³ بأن أساس تطبيق مبدأ حسن النية خلال فترة المفاوضات راجع إلى التصرف القانوني فقط. وقد حاول هذا الاتجاه تحليل كيفية نشوء هذا

1 رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 56؛ ونجد تطبيقاً عملياً بهذا الخصوص، من خلال الإشكال الذي أثير في الفقه فيما لو تمت رشوة المتفاوض الآخر خلال فترة المفاوضات بغية التوصل إلى إبرام العقد، "فما هو أثر الرشوة على العقد المبرم، هل يظل صحيحاً باعتبار أن ما تم من رشوة للمفاوض قد وقع خلال فترة المفاوضات، أم أن هذا العقد سيكون مصيره البطلان، وإذا قيل ببطلان هذا العقد فما هو سبب هذا البطلان". وقد تمت الإجابة عليه بالآتي: "إن القول بصحة مثل هذا العقد يصعب التسليم به حتى وإن استند على اعتبار أن ما تم من رشوة قد تم في المرحلة السابقة للعقد النهائي، لأن هذا العقد قد استند على رشوة.. والاتفاق على الرشوة باطل لأنه يخالف الآداب العامة.....". نقلاً عن حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 863.

2 حيث يستند هذا الرأي إلى الصيغة الوجوبية التي استخدمها المشرع الأردني لإلزام الأطراف بمبدأ حسن النية أثناء فترة تنفيذه في نص المادة (202) من القانون المدني الأردني الآتي: "1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، والتي تقابلها المادة (246) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي والمادة (148) من القانون المدني المصري؛ ونجد من يفسر ذلك بالقول: "أنه طالما كان التفاوض لازماً للعقد فهو ما ينطبق عليه مبدأ حسن النية وينسحب أثر حسن النية بتنفيذ العقد نحو التفاوض على العقد باعتبار التفاوض من مستلزمات العقد، لا سيما إذا كنا بصدد عقد تجاري دولي ذو طبيعة معقدة". رأي لى محمد أحمد المبيضين، مرجع سابق، ص 81.

3 محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 46.

التصرف، فأستندوا سبب نشوئه إلى نظرية العقد الضمني¹، في حين يسند جانب آخر أساس ظهور هذا التصرف القانوني إلى نظرية الشرط الضمني².

وبخصوص موقف القانون والفقه المقارن المتقدم بشأن أساس التزام الأطراف بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد؛ فإني أؤيد الجانب الذي يرى بأن أساس هذا الالتزام راجع لمضمون هذا المبدأ بحد ذاته، والذي نعتقد بأنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من قواعد النظام العام، نظراً لارتباطه الوثيق بالأسس الأخلاقية، والدينية، والاجتماعية، والاقتصادية التي يقوم عليها المجتمع. وعلى هذا الأساس، لا يجوز للأطراف الاتفاق بداءةً على خلاف ما يقتضيه هذا المبدأ من مقتضيات أو الاتفاق على إعفاء أحد الأطراف أو كلاهما من الالتزام بمقتضياته أثناء سير المفاوضات. إلا أن ذلك، لا يمنع من أن يلزم الأطراف أنفسهم بهذا الالتزام في عقد تفاوض، حينها تصبح طبيعته عقدية، أو أن يتدخل القانون في فرض هذا الالتزام على المتفاوضين، فيصبح التزاماً قانونياً كما هو الشأن في المادة (1104) من القانون المدني الفرنسي آنفة الذكر. مع الجدير بالتنويه هنا، بأنه لا يوجد ما يمنع من إعمال هاتين الطبيعتين معاً، فكلأ

1 تقسم نظرية العقد الضمني الإيجاب إلى نوعين، أما الأول فموضوعه العقد محل التفاوض، وأما الثاني فمضمونه عدم إعاقة هذا العقد. وتفترض هذه النظرية بأن الإيجاب الثاني مقرر دائماً لمصلحة الموجب له، لذلك، فهي تعتبر سكوت الموجب له قبولاً ضمناً منه على هذا الإيجاب. وبمجرد تطابق القبول مع الإيجاب ينشأ العقد الضمني، الذي يرتب بمجرد انعقاده التزاماً ضمناً بين الأطراف بعدم إعاقة إبرام العقد المستقبلي. ويعتبر التقصير في هذا الالتزام خطأً عقدياً، يستوجب معه قيام المسؤولية العقدية. لمزيد من التفصيل حول نظرية العقد الضمني انظر ذات المرجع، ص 46-47.

2 يرى هذا الاتجاه، بأن هناك شرطاً ضمناً يتكون بين الأطراف؛ بمجرد اتفاقهم الصريح أم الضمني في الدخول في مفاوضات. وبموجبه يلتزم الأطراف بالسير في المفاوضات، وعدم قطعها بدون سبب جدي. فإذا أخل أحدهم بهذا الالتزام، وجب عليه تعويض الطرف الآخر عن فوات هذه الفرصة. للتفصيل حول نظرية الشرط الضمني انظر ذات المرجع، ص 47-48.

منها تساند الأخرى في إلزام الأطراف بالتقيد بحسن النية في التفاوض. ولا شك، بأن تحديد طبيعة مسؤولية الإخلال بمبدأ حسن النية في المراحل السابقة على التعاقد -موضوع هذه الدراسة-، لا يتوقف على دراسة مفهوم هذه المراحل، وتحديد الحد الفاصل بينها، والأساس الذي يستند إليه لفرض هذا المبدأ على الأطراف خلال المراحل السابقة على التعاقد كما سلف؛ بل يتطلب هذا الأمر أيضاً دراسة طبيعة المسؤولية القانونية خلالها، على النحو الذي سنبينه في المبحث التالي.

المبحث الثاني

طبيعة المسؤولية القانونية في المراحل السابقة على التعاقد

إن تحديد نوع المسؤولية القانونية المطبقة على الفترة قبل العقدية، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديد طبيعة المفاوضات، فيما إذا كانت عقدية أم تقصيرية، حيث تختلف طبيعة قواعد المسؤولية باختلاف طبيعة المفاوضات¹.

وقد تدرج الفقه - في بداية الأمر- في اعترافه بالمفاوضات كمرحلة من مراحل العقد، حيث كان الفقه في السابق، لا يعترف نهائياً بالمفاوضات، ويعتبرها مجرد وقائع مادية، لا قيمة لها، لعدم وجود عقد خلال تلك الفترة. لكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة في الفقه المعاصر²، بالتزامن مع التطور الحاصل في أغلب العقود في وقتنا الحالي، والتي تتطلب طبيعتها إجراء مفاوضات مسبقة، للتمكن من إبرامها، فأصبح يعترف بالمفاوضات قبل العقدية، رغم اختلافه في تحديد طبيعتها القانونية؛ وفي تحديد أحكام المسؤولية القانونية المفترض تطبيقها خلال هذه المراحل³.

المطلب الأول

المسؤولية القانونية المطبقة على المفاوضات

بموجب عقد تفاوض ضمني

قد يحدث عادة أن يدخل الأطراف مباشرة في مفاوضات فيما بينهم، دون أن يكون بينهم تنظيم اتفاقي مكتوب وصريح، يحدد فيه الأطراف كافة إجراءات وشروط عملية

1 أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 30.

2 باستثناء الفقه الإنجليزي والأمريكي كما سبق بيانه، فلم يتغير رأيهم بخصوص المفاوضات، كونها تعتبر في نظرهم أعمالاً مادية لا يترتب عليها أي أثر قانوني. انظر ذات المرجع، صص 37-38 و34.

3 محمود أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 41.

التفاوض¹. وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعة هذه المفاوضات، نظراً لعدم وجود نصوص قانونية في أغلب التشريعات المدنية تنظم المفاوضات، كقانون المعاملات المدنية الاتحادي، ونظيره القانون المدني المصري والأردني. وفي هذا الصدد، انقسم الفقه المقارن إلى اتجاهين؛ نبيين في الفرعين التاليين:

الفرع الأول اتجاه لا يعترف بالطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني

يفرق الاتجاه الأول في الفقه² في اعترافه بالطبيعة العقدية للمفاوضات بين المفاوضات بموجب عقد تفاوض صريح؛ والمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني. أما النوع الأول من المفاوضات فتعتبر في نظرهم ذات طبيعة عقدية، وهي ملزمة للطرفين، استناداً إلى العلاقة التعاقدية التي تنشأ بينهم بمجرد إبرام عقد تفاوض، والتي تخضع لقواعد المسؤولية العقدية. أما النوع الثاني وهي المفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني، فهم يعتبرونها ذات طبيعة مادية بحتة، وهي غير ملزمة على الأطراف، لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهم. وبالتالي، يجوز لكل طرف مشارك في هذه المفاوضات الانسحاب منها في أي وقت، دون أن يكون ملتزماً بتبرير موقفه، أو أن يتحمل أية مسؤولية قانونية نتيجة هذا الانسحاب، إلا إذا كان متعسفاً في انسحابه، أو صدر عنه خطأ مستقل عن عدوله؛ تسبب في إلحاق الضرر بالطرف الآخر، مما يستوجب معه مساءلته طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا ما توافرت شروطها.

1 حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 844؛ أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 30؛ محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 41؛ رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 26.
2 ذات المرجع، ص 844؛ ذات المرجع، ص ص 30-31.

وعلى خلاف ما تقدم، نرى بأن إثبات الصفة العقدية لأي من الالتزامات الناشئة عن عقد التفاوض الضمني، من شأنه أن يدحض رأي الاتجاه الذي لا يعترف بالطبيعة العقدية للمفاوضات القائمة على هذا العقد. وفي هذا الصدد، نتناول بالدراسة بعض أقوال الجانب المعارض للطبيعة العقدية للالتزام بالإعلام قبل التعاقد¹؛ باعتباره أحد أهم التزامات مبدأ حسن النية في العقد، ومن ثم أحد التزامات العقد الضمني؛ ونحاول الرد عليها في سبيل إثبات الصفة العقدية لهذا الالتزام على أساس العقد الضمني، والذي سيجري عليه اعتبار المفاوضات عقدية. ومن هذه الأقوال، القول بأن هذا الالتزام ما هو إلا وسيلة يلجأ إليها البائع لضمان علم المشتري بالمبيع، وصفاته، وكيفية استعماله، وتجنب مخاطره على النحو الذي يضمن تحقق ركن الرضا طبقاً لما تقرره القواعد العامة لصحة انعقاد العقود، الأمر الذي يوضح دوره في تكوين العقد قبل إبرامه، مما يؤكد ذلك صفته غير العقدية². ونرى، بأن هذا الأمر لا علاقة له بطبيعة الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، كما أن تدخل الالتزام في تكوين الرضا بالعقد النهائي، لا يعني بأن الأخير هو أساس هذا الالتزام، لذلك ينبغي التفريق بين العقد النهائي المراد إبرامه، وبين مصدر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وهو مبدأ حسن النية، سواء صدر عقد تفاوض صريح أم ضمني؛ وفي حال صدور هذا العقد لا شك بأن طبيعته تصبح عقدية استناداً لهذا العقد.

1 تعددت التعاريف الواردة في الفقه حول الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، نذكر من بينها التعريف الآتي: "هو أن يقوم كل طرف بالافضاء إلى الطرف الآخر بكل ما يحوزه من بيانات ومعلومات تتعلق بالعقد المتفاوض عليه وذلك حتى يتسنى للطرف الآخر أن يُقدم على التعاقد بإرادة سليمة ومتنورة" نقلاً عن عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 276.

2 ذات المرجع، ص 69.

كما جاء في قول آخر للاتجاه المعارض للطبيعة العقدية للالتزام بالإعلام قبل التعاقد بأنه من غير الصحيح ربط الخطأ الصادر في المراحل السابقة على العقد بالعقد النهائي، لأنه قد يعرض صحة هذا العقد للخطر¹، إعمالاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل. ونرى بأن هذا الاعتراض قد يكون منطقياً في حال أُسست طبيعة الالتزام بالإعلام قبل التعاقد على العقد النهائي؛ إلا أن هذا القول غير منطقي، فهذا الالتزام نشأ أصلاً في الفترة السابقة على انعقاد العقد النهائي، فكيف يكون الأخير سبب نشوئه؟ لذلك نرى بأن سبب نشوء هذا الالتزام هو عقد التفاوض سواء نشأ هذا العقد صراحةً، أم ضمناً وفقاً لما تقرره القواعد العامة لانعقاد العقود، ويستتبع ذلك بالضرورة اعتبار مرحلة المفاوضات عقدية، وانسحاب هذه الطبيعة للمرحلة التي تليها وهي مرحلة إبرام العقد باعتبارها مرحلة تكميلية يتم فيها استكمال ما تم التوصل إليه في مرحلة المفاوضات.

وعلى خلاف ذلك، ذهب اتجاه مؤيد للطبيعة العقدية للالتزام بالإعلام قبل التعاقد إلى القول بأن تجزئة طبيعة هذا الالتزام على مراحل العقد السابقة واللاحقة على انعقاده؛ سيؤدي إلى تجزئة قواعد المسؤولية المفترض تطبيقها على هاتين المرحلتين، ويستتبع ذلك بالضرورة اختلاف إجراءات رفع دعوى المسؤولية، نظراً لاختلاف قواعد كل منها، ولا شك بأن هذا الأمر سيضر الدائن بالإعلام في حالة قيامه بمطالبة المدين بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة إخلاله بالتزامه بالإعلام، فيما لو امتد هذا الإخلال من الفترة السابقة على التعاقد، ولغاية تنفيذ العقد، حيث سيؤدي ذلك فعلياً إلى رفع دعويين مختلفتين بهذا الخصوص، الأمر الذي سيؤثر سلباً على مصالحه وحقوقه. ونرى بأن هذا الأمر يتوقف تحديده على طبيعة الالتزام

1 رأي مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، كلية الحقوق - جامعة طنطا، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010، ص 69.

بالإعلام قبل التعاقد ذاته، فإذا كانت طبيعته عقدية، فإنه لا شك سيخضع لقواعد المسؤولية العقدية، وبخلاف ذلك سيطبق بشأنه قواعد المسؤولية التقصيرية لجبر الضرر الناشئ عن الإخلال به.

ونظراً لعدم تنظيم المشرع الإماراتي، ونظيره المصري والأردني للمفاوضات بصفة عامة، وللالتزام بمبدأ حسن النية خلالها بصفة خاصة كما تقدم، وبالتالي عدم وضوح موقفه بشأنها، نخصص الغصون التالية للاطلاع على تكييف القضاء الإماراتي، والمصري، والأردني للمفاوضات غير المصحوبة باتفاق صريح:

الغصن الأول موقف القضاء الإماراتي

عبرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات في أحكامها عن موقفها بهذا الخصوص، نذكر منها الحكم الآتي: "إنه ولئن كانت المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني فكل متفاوض حر في قطع المفاوضات في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسؤولية أو يطالب ببيان المبرر لعدوله ولا يترتب هذا العدول مسؤولية على من عدل إلا إذا اقترن بخطأ تتحقق معه المسؤولية التقصيرية إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوض وتوافر به عنصر الخطأ اللازم لقيام المسؤولية التقصيرية..."¹.

كما أشارت ذات المحكمة في حكم آخر لها بالآتي: "... وأن هذا الخطاب جاء في مرحلة المفاوضات التي سبقت التوقيع على عقد الصلح مما يعني أنه مجرد من كل أثر قانوني..."².

1 المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات-الأحكام المدنية والتجارية-الطعن رقم 312 لسنة 19قضائية-الدائرة المدنية والتجارية-بتاريخ 12-01-1999 مكتب فني 21رقم الجزء 1 رقم الصفحة 29 [نقض الحكم والإحالة] رقم القاعدة 7، الرقم المرجعي للحكم في شبكة قوانين الشرق: 61365، تاريخ الاطلاع: 19/09/2023.

2 المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات-الأحكام المدنية والتجارية-الطعن رقم 195 لسنة 1995

ونلاحظ ذات التوجه في أحكام محكمة نقض أبو ظبي؛ حيث جاء في أحد أحكامها الآتي: "... وأن ما يسبق العقد من مفاوضات ومطالبات ورسائل متبادلة بين المتعاقدين ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليهما أثر قانوني، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تحضير أو تمهيد للعقد، وأن العبرة بما تتمخض عنه هذه المفاوضات من اتفاق وشروط ينص عليها في العقد باعتبار أن هذه المفاوضات تعتبر قرينة دالة على نية المتعاقدين فهي تخضع كسائر باقي القرائن الأخرى المطروحة في الدعوى لتقدير محكمة الموضوع. ومن المقرر أن تكييف ما يعد عقداً أو مفاوضة أو دعوة للتعاقد من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع في شأنها إلى رقابة محكمة النقض..."¹.

هذا، وقد بررت محكمة نقض أبوظبي سبب اعتبار المفاوضات أعمالاً مادية بالقول: "... باعتبار أن الهدف من المفاوضات السابقة على العقد هو التحضير والتمهيد والدعوة إلى التعاقد لأن كثيراً من العقود تحتاج إلى الأناة وإمعان النظر، ولا إلزام على الطرفين خلالها بالاستمرار فيها ويجوز لأيهما العدول عنها، على أن العدول عن المفاوضات قد يترتب مسؤولية من قطعها إذا اقترن هذا العدول بخطأ صدر منه ترتب عليه الإضرار بالطرف الآخر، ومصدر هذه المسؤولية ليس هو قطع المفاوضات

==

19 قضائية-الدائرة المدنية والتجارية-بتاريخ 20-10-1998 مكتب فني 20 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1009 [نقض الحكم والتصدي للموضوع] رقم القاعدة 173، الرقم المرجعي للحكم في شبكة قوانين الشرق: 49739، تاريخ الاطلاع: 19/09/2023.

1 محكمة نقض أبو ظبي- الطعن رقم 208 لسنة 2018 س 12 ق. أ - جلسة 2 / 4 / 2018 (تجاري)؛ والطعن رقم 352 لسنة 2017 س 11 ق. أ - جلسة 31 / 10 / 2017 (تجاري)؛ وكذلك الطعن رقم 885 لسنة 2016 س 11 ق. أ - جلسة 16 / 3 / 2017 (تجاري)؛ وانظر أيضاً حكم محكمة تمييز دبي- الطعن رقم 131 لسنة 2013 (تجاري) - بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2013؛ وحكم محكمة تمييز دبي- الطعن رقم 246 لسنة 2007 (طعن تجاري) جلسة الثلاثاء 5 / فبراير 2008 /، جميع الأحكام مشار إليها في موقع محامو الامارات، تاريخ الاطلاع 24/9/2023.

في ذاته وإنما هو الخطأ الذي ارتكبه من عدل عنها، والمكلف بإثبات هذا الخطأ والضرر هو الطرف الذي أصابه ضرر. وإن تكييف ما يعد عقدًا أو مفاوضة أو دعوة إلى التعاقد من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع في شأنها إلى رقابة محكمة النقض"¹.

الفصل الثاني موقف القضاء المصري

بالنسبة لموقف القضاء المصري من المفاوضات غير المصحوبة بعقد تفاوض صريح، فما زال لا يعترف بهذا النوع من المفاوضات، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، حيث تؤكد محكمة النقض المصرية ذلك في العديد من قراراتها، كما هو الشأن في الحكم الآتي الذي عبرت فيه عن رأيها حول طبيعة المفاوضات بقولها: "... وإن المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً ولا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني..."².

كما بينت ذات المحكمة في حكم آخر لها أحكام المسؤولية القانونية التي ينبغي إعمالها للتعويض عن الضرر الناتج عن هذا النوع من المفاوضات، وفقاً للتفصيل الآتي: " هذا الذي تأسس عليه قضاء الحكم بمسؤولية الطاعن ينطوي على مخالفة للقانون وقصور في التسبب ذلك أن المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها

1 محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم 784 لسنة 2011 س 6 ق. أ - جلسة 14/06/2012 (تجاري)؛ مشار إليه لدى موقع محامو الامارات، تاريخ الاطلاع: 24/09/2023.

2 محكمة النقض المصرية- مدني- الطعن رقم 8240 لسنة 65 قضائية بتاريخ 23-06-1997 مكتب في 48 الجزء 2 رقم الصفحة 952 [رفض] رقم القاعدة 184، الرقم المرجعي للحكم في شبكة قوانين الشرق: 14083، تاريخ الاطلاع: 19/09/2023؛ كما أشارت ذات المحكمة في حكمين آخرين لها، " بأن التفاوض غير المصحوب باتفاق سابق وصريح ما هو إلا مجرد عمل مادي غير ملزم". انظر: نقض مدني مصري، تاريخ 9/فبراير 1967 /، السنة 18، وكذلك نقض مدني مصري، تاريخ 28/ مارس / 1968، السنة 19، نقلاً عن رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 26.

بذاتها أي أثر قانوني فكل متفاوض حر في المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسؤولية أو يطالب ببيان المبرر لعدوله ولا يرتب هذا العدول مسؤولية على من عدل إلا اذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسؤولية التقصيرية إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوض- وفي هذه الحالة يقع عبء اثبات ذلك الخطأ وهذا الضرر على عاتق ذاك الطرف ومن ثم فلا يجوز اعتبار العدول عن إتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره- بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسؤولية التقصيرية..."¹.

الغصن الثالث موقف القضاء الأردني

لم يختلف موقف محكمة التمييز الأردنية عن المحاكم أنفة الذكر، فهي كذلك لا تعترف بالمفاوضات غير المصحوبة بعقد تفاوض صريح، وهي في نظرها لا ترقى لمستوى العقد. حيث عبرت عن ذلك في أحد قراراتها على النحو الآتي: "إن انعقاد العقد صحيحاً بين طرفيه ولم تجر اية اقالة لهذا العقد لا بالتراضي أو التقاضي إذا كان ما جرى بين أطراف العقد ليست إلا عبارة عن مفاوضات لم تتم الإقالة.... أما قول المميّزة بأنها عينت مديراً للتأجير والتفاوض نيابة عنها فإن ذلك هو قول مجرد لم يتم الاتفاق عليه فيما بين الطرفين على هذا الأساس للتوصل إلى إقالة العقد"².

1 محكمة النقض المصرية- مدني- الطعن رقم 167 لسنة 33 قضائية بتاريخ 09-01-1967 مكتب في 18 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 334 (نقض الحكم والإحالة) رقم القاعدة 52، الرقم المرجعي للحكم في شبكة قوانين الشرق: 3252، تاريخ الاطلاع: 20/9/2023.

2 المملكة الهاشمية الأردنية- تمييز حقوق رقم 2423 -2011، منشورات مركز عدالة. نقلاً عن رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص ص 51-52.

كما أكدت في أحد قراراتها ما تقدم بالقول: "وثبت ذلك من قيود الشركة وحساباتها ونشرة إصدارها وميزانيتها العامة ومن البيئة الشخصية التي جاءت لإثبات الوقائع المادية وهي وقائع التكليف والتفاوض التي يجوز قانوناً إثباتها بالبيئة الشخصية"¹. وكذلك بقولها في حكم آخر: "إذا لم يصدر قرار عن لجنة العطاءات في مديرية الأمن العام بإحالة العطاء موضوع الدعوى على المميز، وأن العطاء تقرر الغائه قبل استكمال كافة مراحل القانونية وأن ما تم ما بين المميز والجهة المميز ضدها لا يعدو عن كونه أعمال تحضيرية ومفاوضات لم تنته إلى إبرام عقد لكي ينتج أثره القانونية"².

ونستنتج مما تقدم، بأن التوجه القضائي في الإمارات ومصر والأردن واحد فهو يعتبر المفاوضات غير المصحوبة باتفاق صريح عبارة عن أعمال مادية لا ترتب أثراً قانونياً، وفي حال صدور خطأ خلالها فيطبق بشأنه قواعد المسؤولية التقصيرية، وبالتالي فهو لا يعترف بفكرة عقد التفاوض الضمني في المفاوضات.

الفرع الثاني اتجاه يعترف بالطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني

يعارض اتجاه آخر في الفقه الاتجاه السابق؛ الذي يفرق بين المفاوضات بموجب عقد صريح، والمفاوضات بموجب عقد ضمني. فهم يرون، بأنه لا يوجد أساس قانوني لهذه التفرقة. بالإضافة إلى ما يحدثه هذا الأمر من ازدواجية في المعيار، والذي يترتب عليه ازدواجية في تطبيق القواعد القانونية، حيث يعتبر التفاوض بدون اتفاق صريح

1 مشار إليه لدى أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 36.

2 المملكة الهاشمية الأردنية- تمييز حقوق رقم 1839-2005، منشورات مركز عدالة. مشار إليه لدى رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 51.

عمل مادي؛ يستوجب معه تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية، بينما يعتبر التفاوض الصريح عمل قانوني؛ يستوجب معه تطبيق قواعد المسؤولية العقدية. ومما لا شك فيه، بأن هذه النتيجة لا ينبغي التسليم بها، فالتفاوض هو ذاته في الحالتين، ويقضي العدل والمنطق تطبيق ذات القواعد القانونية عليه، دون تمييز بينها بدون سند قانوني¹.

كما يرى الاتجاه المؤيد للطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني، بأن التقسيم المشار إليه نتيجة التفرقة بين طبيعة المفاوضات بموجب عقد صريح، والمفاوضات بموجب عقد ضمني، يعتبر أمراً مخالفاً لما تقرره القواعد العامة لانعقاد العقد بصفة عامة. فالأصل في العقود الرضائية، ولا يشترط لقيامها الكتابة، إلا إذا نص القانون على ذلك. ومن ثم، يكفي لقيام العقد أن يعبر الطرفان عن إيجاب وقبول متطابقين، حتى ولو كان هذا التعبير ضمناً. وتطبيقاً لذلك، قد يكون اتفاق التفاوض صريحاً، إذا ما قام الطرفان بصياغة بنود وأحكام عملية التفاوض بينهم، كما قد يكون ضمناً، في الحالة التي يتغاضى فيها الطرفان عن كتابة هذا الاتفاق، أو التصريح عنه بصورة واضحة، لكنهم في ذات الوقت يتخذون كافة الخطوات العملية والإجراءات اللازمة للسير في عملية المفاوضات. وبالتالي، فإن الأخذ بفكرة الطبيعة المادية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني؛ من شأنه أن يخالف المفهوم

1 محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، صص 47-48 و 43-44؛ حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 845؛ رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 27؛ هذا، وقد استند الفقه الألماني في اعترافه بالطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني على نظرية الخطأ التي قال بها إيرنج، وبموجب هذه النظرية تنشأ علاقة قانونية بين الطرفين بمجرد دخولهم في مفاوضات جدية. وترتب هذه العلاقة بعض الالتزامات على المتفاوضين من بينها الالتزام بحسن النية أثناء التفاوض، فإذا أحل أحد الطرفين بتنفيذ هذه الالتزامات، وجب تطبيق قواعد المسؤولية العقدية. للمزيد من التفصيل انظر أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، صص 44 و 33-34.

القانوني الصحيح للمفاوضات، فالتفاوض لا يتم بمحض الصدفة؛ ومن غير المنطق أن يجد المتفاوضان أنفسهما فجأة على طاولة المفاوضات دون أن يكون بينهما اتفاق سابق. فهذا الاتفاق يتكون نتيجة توافق إرادتين أو أكثر، بقصد إحداث أثر قانوني، وهو التوصل إلى إبرام العقد محل التفاوض، كما يترتب عليه التزامات وحقوق حقيقية، وهو بذلك يتفق مع المفهوم العام للعقد¹.

فضلاً على أنه يترتب على تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية على المفاوضات؛ وجوب تحقق خطأ مستقل عن قطع المفاوضات لتقدير التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، وهذا ما لا ينبغي التسليم به، فهناك حالات للعدول تجعل صاحبها مسؤولاً عن عدوله، وإن لم يقترن فعله بخطأ مستقل عنه، كحالة العدول في المفاوضات التي شارفت على الانتهاء بدون مبرر².

كما يستند مؤيدو الصفة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني في رفضهم تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية عليها إلى صعوبة إثبات الخطأ التقصيري في هذه المرحلة، إلا إذا اعتبر فعل العدول بحد ذاته خطأً يوجب المسؤولية التقصيرية، ومن غير المتصور الأخذ بهذه النتيجة، لما في ذلك من توسع في نطاق المسؤولية التقصيرية، وفي هذا الأمر خطورة على الحريات الفردية، وعلى مبدأ حرية التعاقد³.

1 حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 846-845؛ محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 44-43؛ أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 46-45؛ رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 29-28.

2 حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 846؛ محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 44.

3 ذات المرجع، ص 847؛ ذات المرجع، ص 44-45.

ومن ناحية أخرى، فإن أعمال قواعد المسؤولية التقصيرية على المفاوضات؛ من شأنه أن يوسع من نطاق المسؤولية، فالتفاوض يصبح -وفقاً لهذه القواعد- مسؤولاً عن الضرر المباشر المتوقع أو غير المتوقع، بخلاف الأمر فيما لو طبقت قواعد المسؤولية العقدية على المفاوضات، والتي تقرر مسؤولية التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط؛ مما يترتب عليه نتيجة غير منطقية، إذ من غير المنطقي التشديد في توسيع نطاق المسؤولية في المرحلة السابقة على العقد، في حين يتم التخفيف من نطاق هذه المسؤولية في المرحلة اللاحقة على انعقاده من خلال تطبيق قواعد المسؤولية العقدية. فضلاً على أنه يترتب على هذا التشديد نفور الناس من الدخول في المفاوضات؛ فلو علم كل شخص بأنه سوف يحاسب على جميع الأضرار المباشرة المتوقعة أو غير المتوقعة نتيجة فشله في المفاوضات، لتجنب الدخول فيها منذ البداية، تفادياً للمشاكل وتحمل عبء المسؤولية التقصيرية)¹.

ومما يؤكد هذا التشديد أيضاً، إمكانية مساءلة المتفاوض ناقص الأهلية عما يرتبه تفاوضه من ضرر فيما لو طبقت على المفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني قواعد المسؤولية التقصيرية، بخلاف لو تم أعمال قواعد المسؤولية العقدية على هذه المفاوضات، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الطبيعة المادية لهذا النوع من المفاوضات.²

وبهذا الخصوص، نستشهد ببعض السوابق القضائية في القضاء المدني الفرنسي التي اعترفت بعقد التفاوض الضمني، ومن هذه السوابق نجد حكماً لمحكمة النقض الفرنسية يقر باتفاق التفاوض الضمني في قضية تتلخص وقائعها، أن أحد عمال

1 حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 846؛ محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 45.

2 ذات المرجع، ص 846؛ ذات المرجع، ص ص 44-45.

مصانع رينو للسيارات، قدم استقالته للمشاركة في الحرب القائمة في بلاده آنذاك، وبعد انتهاء هذه الحرب، طالب الشركة بإرجاعه إلى العمل، لكنها تعذرت بعدم إمكانية ذلك نظراً لظروف الشركة، وبعد وساطة شخص من الغير، صدر عن هذه الشركة خطاب تتعهد فيه بإرجاعه إلى العمل في حال كان نشاط الشركة يسمح بذلك، إلا أنها لم تفعل رغم تحسن وضعها الاقتصادي، "وبعرض الأمر على محكمة الموضوع قضت الأخيرة بأن تعهد الشركة الوارد في هذين الخطابين هو تعهد نهائي يلزمها بإعادة العامل إلى العمل بالفعل. إلا أن محكمة النقض أنعت هذا الحكم وقررت أن هذا التعهد لا يعدو أن يكون اتفاقاً مبدئياً يلزم الشركة فحسب بأن تبحث مع العامل مدى إمكانية اعادته إلى العمل في ضوء الظروف الاقتصادية للمشروع. وهكذا اعترفت محكمة النقض الفرنسية صراحة لأول مرة بوجود اتفاق مبدئي أي اتفاق تفاوض بين الطرفين. ومن الواضح أن الطرفين لم يصرحا بهذا الاتفاق ولكن المحكمة استخلصته ضمناً من خطابي الشركة المرسلين إلى العامل رداً على عرضه إليها بالعودة إلى العمل. وبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية قد أقرت بهذا الحكم فكرة اتفاق التفاوض الضمني"¹.

كما نجد حكماً آخر لذات المحكمة في قضية تتلخص وقائعها "في أن مؤسسة Pigassou اتفقت مع مؤسسة Bergel على أن تؤجر لها محلاً تجارياً لمدة عام. ولما دب الخلاف بينهما حول بعض التفاصيل رفع الأمر إلى القضاء حيث تمسكت مؤسسة (P) بأن ما اتفقت عليه مع مؤسسة (B) هو مجرد شغل مؤقت للعين المؤجرة لحين إبرام

1 انظر:

-Cass.soc.24 mars 1958.Regie nationale des usines Renault Mar-chal
J.C.P.1958.II.10868.OBS Carbonnier(J)

نقلاً عن عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص ص 244-245.

عقد الايجار النهائي في حين ادعت مؤسسة (B) أن عقد الايجار قد انعقد بالفعل ويجب تنفيذه. وقد أيدت محكمة النقض قضاة الموضوع في رفضهم ادعاء مؤسسة (B) مع الحكم في ذات الوقت على مؤسسة (P) بالتعويض. والشيء الهام في هذا الحكم هو الأساس الذي بنى عليه الحكم بالتعويض فقد اعتبرت المحكمة أن مؤسسة (P) قد أخلت بالتزامها العقدي بالتفاوض بحسن نية وذلك لأنها لم تطلع مؤسسة (B) على الشروط التي ترغب في التعاقد على أساسها مما أدى إلى فشل التفاوض بينهما. فما تم بين الطرفين إذن لم يكن عقد إيجار نهائي لأنهما لم يتفقا على كل شروطه وإنما اتفقا فحسب على التفاوض من أجل إبرامه. وغني عن البيان أن هذا الاتفاق على التفاوض هو اتفاق ضمني استخلصته المحكمة من ظروف الحال¹.

وفي هذا الصدد، نذكر أيضاً قرار محكمة استئناف فرساي في القضية المشهورة باسم "ساندوز" حيث أكدت في قرارها بأن "تبادل الأطراف لمشروعات العقد يعد عقد تفاوض وتنشأ عنه التزامات تعاقدية حقيقية، وإذ قامت مجموعة شركات "ساندوز" بقطع المفاوضات بعد أن قطعت شوطاً طويلاً امتد لما يقارب الأربع سنوات، وبدون مبرر جدي وموضوعي فإنها تكون قد خالفت التزاماتها المترتبة عليها بموجب عقد التفاوض. وبأنها بتركها شركة بوليفال تأمل بإبرام العقد (إنتاج أدوية بطريقة تصنيعية خاصة)، لمدة أربع سنوات فإنها تكون خالفت مقتضيات الشرف وحسن النية وتسببت بضرر لشركة بوليفال، وبما يوجب إلزامها بالتعويض"².

1 انظر:

-Cass civ 16 avr 1973 . Bull. civ. N 287.p.207.

نقلاً عن عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 247.

2 انظر: القرار الصادر عن محكمة استئناف فرساي في 21/9/1995 وأيدته الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 إبريل 1998،

==

وفي ذات السياق، أصدرت محكمة استئناف باريس في قضية "تتلخص وقائعها في أن شركتين اتفقتا على الدخول في التفاوض من أجل الاندماج فيما بينهما. وبعد عدة جلسات قامت إحدى الشركتين بإخطار الشركة الأخرى بانسحابها من المفاوضات. وبعرض النزاع على التحكيم قضى التحكيم بعدم مسئولية الشركة المنسحبة من المفاوضات. وعندما طعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف باريس قضت المحكمة بتأييده. وقد سلمت المحكمة في حيثيات الحكم بوجود اتفاق تفاوض بين الطرفين ينشئ على عاتقهما التزاما تعاقديا بالتفاوض بحسن نية إلا أنها رأت مع قرار التحكيم ألا ترتب مسئولية على عاتق الشركة التي قطعت المفاوضات وذلك لكونها لم تخل بقواعد حسن النية السائدة في المعاملات التجارية حيث أنها قد أخطرت الشركة الأخرى في الوقت المناسب بعزمها العدول عن المفاوضات فضلا عن أن الاتفاق على التفاوض لا يلزم الطرفين البتة بإبرام العقد النهائي بالفعل"¹.

ومن جانبنا، نؤيد الاتجاه الفقهي الذي يسبغ الطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني شأنها في ذلك شأن المفاوضات بموجب عقد تفاوض صريح ومكتوب، فهي تنشأ بمجرد صدور قبول مطابق من المتفاوض الآخر للإيجاب بالتفاوض الصادر من الطرف الراغب في الدخول معه في مفاوضات جدية بخصوص عقد ما. وعلى هذا الأساس تنشأ رابطة عقدية بين الطرفين، يحكمها عقد تفاوض

==

- Cass.com.7avril 1998 n 95-20,361. J.C.P.E. 1999, p579

نقلًا عن لى محمد أحمد المبيضين، مرجع سابق، ص 72؛ انظر تفصيل وقائع هذه القضية: أبحار حامد حبش، مرجع سابق، ص ص 32-33.

1 انظر:

C.A. paris 18 Janv 1996.D. A. 1996.p. 292.-

مشار إليه لدى عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 246.

ضميني. ولا يمس ذلك بالمبادئ المستقر عليها في التعاقد، كمبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ حرية التعاقد. فالغاية الأساسية من عقد التفاوض -الضميني والصريح- هي تنظيم مجريات المفاوضات فيما بين الطرفين، وتحديد حقوق والتزامات كلا منهما خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إلزام الطرفين باحترام مبدأ حسن النية، وبإتيان الالتزامات الأخرى المتفرعة عنه أثناء قيامهما بالتفاوض، وليست الغاية منه فرض التزام على الطرفين بالاستمرار في التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن العقد المراد إبرامه.

فإذا أخل أحد أطراف التفاوض بما يفرضه هذا العقد من التزامات، كأن يقوم بأي فعل يخالف مقتضيات مبدأ حسن النية، جاز للطرف المتضرر أن يطالبه بجبر الضرر الذي أصابه إزاء مخالفته هذه، وذلك طبقاً لما تقرره قواعد المسؤولية العقدية لا التقصيرية وفقاً لما تقدم، إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي هذا التعويض إلى إجبار الطرف المخل بإبرام العقد النهائي.

وبعد بحث طبيعة المفاوضات بموجب عقد تفاوض ضميني على النحو المتقدم، ننتقل للمطلب الثاني لبحث الخلاف الفقهي الدائر في الفقه بخصوص طبيعة المسؤولية المطبقة على المفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض صريح.

المطلب الثاني المسؤولية القانونية المطبقة على المفاوضات بموجب عقد تفاوض صريح

يتعين لتحديد نوع المسؤولية القانونية للمفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض صريح، التعرف أولاً على رأي الفقه والقضاء حول طبيعة هذا النوع من المفاوضات، وفقاً لما سنبينه في الفرعين التاليين.

الفرع الأول

الطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض صريح

وعلى عكس الخلاف الحاصل في الفقه بالنسبة لطبيعة المفاوضات بموجب عقد ضمني؛ لم يختلف الفقه¹ في إسباغ الطبيعة العقدية على المفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض صريح، التي يوضح فيها الطرفان بشكل مسبق ومكتوب، كافة شروط وأحكام عملية التفاوض على عقد معين، معتمدين في ذلك على عقد التفاوض المبرم بينهم. فهذا العقد هو الذي يحكم العلاقة بين المتفاوضين؛ وهو الذي يضي الطابع العقدي على المفاوضات، فيحولها من عمل مادي غير ملزم، إلى عمل قانوني ملزم، وعلى هذا الأساس، تتحول المسؤولية من مسؤولية تقصيرية إلى مسؤولية عقدية².

وهذا، ما أخذت به المحكمة الاتحادية العليا، حيث اعترفت بالاتفاق المبدئي المبرم بين الطرفين خلال فترة المفاوضات، واعتبرته عقداً كسائر العقود، كما هو الشأن في أحد قراراتها الذي أيدت فيه موقف محكمة الإحالة في اعترافها بالطبيعة العقدية لخطاب النوايا، وألزمت الطرف المخل بالتزامه بجبر الضرر الناشئ عن إخلاله وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية لا التقصيرية³. ونلاحظ نفس التوجه في حكم آخر لذات

1 كما هو الحال في الفقه الفرنسي الذي اعترف صراحةً باتفاق التفاوض المكتوب، واعتبره أساس الالتزامات الواقعة على الطرفين خلال فترة المفاوضات، وعلى هذا الأساس يسأل الطرف المخل بتنفيذ التزاماته وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية. وقد سار الفقه المصري على نفس النهج، حيث اعترف بالطبيعة العقدية للمفاوضات المصحوبة باتفاق تفاوض صريح، رغم عدم اعترافه بالمفاوضات بموجب عقد تفاوض ضمني. انظر أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 39-36؛ ولزيد من التفصيل حول هذه الجزئية انظر رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 34-27.

2 حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 844-845؛ أبحار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 36؛ عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 272؛ محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 43؛ رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص 27.

3 المحكمة الاتحادية العليا- الأحكام المدنية والتجارية- الطعن رقم 516 لسنة 21 قضائية-الدائرة
==

المحكمة، حيث اعترفت بخطاب التعيين، واعتبرته اتفاقاً مبدئياً بين الطرفين خلال فترة تفاوضهما، على النحو الآتي: "وتأسيساً على ذلك فإن خطاب التعيين حسبما أشرنا سابقاً المتضمن استحقاق مكافأة سنوية بواقع... يعد اتفاق مبدئي وعلاوة على ذلك فإن كافة العقود التي حررها المدعي لم يرد بها ذكر لتلك النسبة... ويكون ما أثاره المستأنف في هذا الصدد ... يتعين رفضه"¹.

ولعل ما تقدم، يفسر لنا سبب اتباع القضاء الإماراتي للتوجه الفقهي السابق والذي لا يعترف بالطبيعة العقدية للمفاوضات إلا إذا صاحبها اتفاق صريح ومكتوب من قبل الأطراف، على إحداث أثر قانوني معين، شريطة أن تتوافر فيه جميع أركان انعقاد العقد بصفة عامة، وشروط صحة انعقاده. فالاتفاق المكتوب في هذه الحالة يعتبر عقداً كسائر العقود الأخرى، ويرتب أثره على جميع الأعمال الصادرة بين الطرفين بصدد تنفيذه على النحو المطلوب. وبخلاف ذلك، تعتبر المفاوضات من قبيل الأعمال المادية، والتحضيرية التي تمهد لإبرام العقد النهائي، لا أثر قانوني لها.

ونلاحظ نفس التوجه في قضاء محكمة النقض المصرية، فهو أيضاً يعترف بالطبيعة العقدية للمفاوضات المصحوبة باتفاق صريح- كما هو الشأن في القضاء الإماراتي- طالما تحقق في اتفاق التفاوض جميع الأركان اللازمة لانعقاد العقد، وشروط صحة انعقاده، وفقاً لما تقرره القواعد العامة في هذا الشأن. ويتضح هذا الموقف في

==

المدنية والتجارية- بتاريخ 12/06/2001 مكتب في 23 رقم الصفحة 1125 (نقض الحكم والإحالة)
رقم القاعدة 166، الرقم المرجعي للحكم في شبكة قوانين الشرق: 62851، تاريخ الاطلاع:
21/10/2023.

1 دولة الإمارات العربية المتحدة، المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 402 لسنة 27 قضائية-الدائرة المدنية، بتاريخ 5/01/2009 رقم الصفحة 10 [رفض]، الرقم المرجعي للحكم في شبكة قوانين الشرق: 340465، تاريخ الاطلاع: 21/09/2023.

الحكم الآتي الذي جاء فيه: "العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني وإسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد..."¹.

وبالنسبة لموقف قضاء محكمة التمييز الأردنية بخصوص المفاوضات المصحوبة باتفاق صريح؛ فإنه لا يختلف عن موقف القضاء الإماراتي والمصري في هذا الشأن، فهو يعترف بهذا النوع من المفاوضات أخذاً في الاعتبار بتوافر الأركان اللازمة لانعقاد العقد بصفة عامة في هذا الاتفاق، ويستشف ذلك في العديد من أحكامها، نذكر منها الحكم الآتي: "إذا تم العقد صحيحاً ومتوافقاً على أركانه وشروط انعقاده ولم تطعن الجهة المميزة بأي من شروط انعقاد العقد أو صحته فيكون لازماً لطرفيه ويتوجب تنفيذ آثاره والتزاماته (المادة 87 والمادة 2/199 من القانون المدني)"².

والجدير بالتنويه بخصوص عقد التفاوض³ بأنه عقد قائم بذاته، يكفي لانعقاده

1 محكمة النقض المصرية- الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786. مشار إليه لدى جهاد صالح العتيبي، القواعد القضائية في شرح القانون المدني-العقد، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن: عمان، الطبعة الأولى، 2014، ص 83.

2 محكمة النقض الأردنية- تمييز حقوق رقم 2003/1685 - تاريخ 2003/10/30 هيئة عامة منشورات عدالة. مشار إليه لدى ذات المرجع، ص 23.

3 ويُعرف عقد التفاوض بأنه "اتفاق يلتزم بموجبه كل طرف في مواجهة الآخر بالبدء أو الاستمرار في التفاوض بشأن عقد معين بهدف إبرامه". كما عرفته غرفة التجارة الدولية بأنه "عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعة التفاوض بغرض التوصل إلى إبرام عقد لم يتحدد موضوعه إلا بطريقة جزئية لا تكفي في جميع الأحوال لانعقاده". كما عرفته محكمة باريس، بأنه: "إن عقد المفاوضة هو عقد بمقتضاه يلتزم أطرافه ببدء أو متابعة التفاوض بحسن نية حول شروط عقد يبرم في المستقبل". مشار لجميع هذه التعاريف لدى عبد العزيز المرسى حمود، مرجع سابق، ص ص 231-232؛ انظر بهذا الخصوص أيضاً رعد أحمد اللوزي، مرجع سابق، ص ص 44-43؛ أبحار حامد ==

وترتيب آثاره القانونية؛ أن يتوافر فيه كافة أركان انعقاد العقد كالرضا والسبب والمحل؛ وأن يتوافر فيه كذلك شروط صحة انعقاده، كالأهلية وانتفاء عيوب الإرادة، وذلك طبقاً لما تقرره القواعد العامة لانعقاد العقد¹. والغاية من إبرام هذا العقد، هي تنظيم عملية التفاوض وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها². وكما هو الشأن في سائر العقود الملزمة للجانبين، فإن عقد التفاوض³ يرتب التزامات متبادلة على عاتق الطرفين من أهمها الالتزام بالتفاوض بحسن نية⁴، وبمقتضاه يلتزم الطرفان بالدخول

==

حبش، مرجع سابق، ص 40-41؛ هذا، واعتبر البعض عقد التفاوض " من العقود الحديثة غير المسماة، وغير المنظمة قانوناً، فهو تصرف قانوني إرادي، يسعى طرفاه لترتيب أثر قانوني منه". نقلاً عن محمد أحمد العكام، مرجع سابق، ص 48.

1 محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 49؛ عبدالعزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 232-233؛ وللمزيد حول تكوين عقد التفاوض أنظر شرف علي خالد بغيرات، مرجع سابق، ص 73-78.

2 حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 845؛ أبجار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 36.

3 ومن الخصائص التي يتميز بها عقد التفاوض أيضاً، بأنه عقد تمهيدي لأنه يمهّد لإبرام العقد النهائي. وبأنه عقد مؤقت، لأن مدته تتوقف على مدة المفاوضات طالّت أم قصرت. كما يتميز أيضاً بعدم تضمينه للمسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد النهائي، ولا حتى للمسائل الثانوية لهذا العقد، وهو بذلك يختلف عن الوعد بالتعاقد. للمزيد من التفصيل في هذه الجزئية انظر محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 51-49؛ وأبجار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 42-41؛ وكذلك حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 849-848؛ عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 234-236؛ رعد أحمد اللوزي، مرجع سابق، ص 44-45.

4 وبموجب الالتزام بالتفاوض بحسن نية، يجب على كل طرف احترام مقتضيات مبدأ حسن النية، كالتحلي بالأمانة، والنزاهة، والصدق، والمحافظة على الثقة المشروعة، واحترام القوانين والنظام العام والآداب، والابتعاد عن الغش والخداع. وعدم استعمال حق العدول عن المفاوضات بسوء نية، بقصد الإضرار بالغير. محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 39؛ مبارك محمد آل فطيح، مرجع سابق، ص 70؛ كما يجب عليه بموجب هذا الالتزام؛ أن يبادر كل طرف بإزالة المراكز القلقة أثناء سير عملية التفاوض، والمقصود بهذا الالتزام أن يقوم كل طرف من تلقاء نفسه بوقف المفاوضات، أو تأجيلها، أو تقديم ضمانات إضافية، فيما لو حدثت ظروف عامة أم خاصة، من

==

في عملية التفاوض، والبدء فيها، ومتابعتها، وفقاً للإجراءات والمدة المتفق عليها، فإن لم يحدد في عقد التفاوض مدة معينة، التزم الطرفان باتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة معقولة. كما يلتزم الأطراف بالقيام بالمفاوضات في المكان المتفق عليه، بالإضافة إلى تحمل نفقات الدراسات الأولية ذات الصلة بعملية التفاوض وبإعداد مشروع العقد النهائي محل التفاوض، وذلك طبقاً لما تم الاتفاق عليه¹.

وبالنسبة لطبيعة الالتزام بالتفاوض بحسن نية فهو التزام بتحقيق نتيجة، وليس ببذل عناية، فلا يتصور أن يبرر المتفاوض عدم تنفيذه لهذا الالتزام؛ بالقول بأنه بذل العناية اللازمة لكي يلتزم بحسن النية أثناء تفاوضه مع الطرف الآخر، إلا أنه لم يستطع ذلك². لذلك، لا يستطيع المتفاوض أن يدرك عن نفسه مسؤولية الإخلال

==

شأنها أن تثير المخاوف أو الشكوك عن قرب عجز المتفاوض الآخر، أو عدم مقدرته فعلياً على تنفيذ التزامات العقد إن أبرم... لمعرفة المزيد حول هذا الالتزام انظر حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 854-855.

1 حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 850.

2 ومن الأعمال التي تدل على سوء النية في المفاوضات: إشاعة آمال كاذبة تبعث ثقة زائفة لدى الطرف الآخر في إبرام العقد محل التفاوض بالرغم من نيته عدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر، أو قطع المفاوضات المتقدمة فجأة ودون مبرر، أو التفاوض لمجرد التسلية أو الدعاية أو لاستطلاع السوق دون وجود نية حقيقية في التعاقد، أو اعتماد أسلوب التسويف وإطالة مدة التفاوض مع العلم بصعوبة الوصول إلى اتفاق، أو طرح أفكار غامضة تؤدي إلى تشتت أفكار الطرف الآخر، أو تقديم اقتراحات من الصعب تحقيقها، أو عدم اتباع السلوك المألوف والمعتاد في التفاوض. عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص ص 273-274؛ حمدي بارود، مرجع سابق، ص ص 850-851؛ سعود فواز ماجد الدرويش، مبدأ حسن النية في عقد التأمين في النظام السعودي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية- كلية الدراسات العليا، الأردن، 2016، ص ص 14-15؛ مبارك محمد آل فطیح، مرجع سابق، ص 70؛ أبحار حامد حبش، مرجع سابق، ص ص 54-55؛ محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 39؛ سماح جبار، حسن النية في التفاوض على العقود، المصدر: دراسات، الناشر: جامعة عمار ثلجي بالأغواط، الجزائر، مجلة محكمة، ع 48، 2016، ص 242.

بالالتزام بالتفاوض بحسن نية، إلا في حالة واحدة فقط وهي إثبات السبب الأجنبي الذي حال دون تنفيذه لهذا الالتزام. ويرجع لقواعد المسؤولية العقدية في حال وجود عقد تفاوض صريح أم ضمني، لجبر الضرر الناشئ عن هذا الإخلال¹.

ونخلص مما تقدم، بأن القضاء الإماراتي والمصري والأردني متفق على عدم الاعتراف بالطبيعة العقدية للمفاوضات إلا إذا صاحبها اتفاق صريح ومكتوب من قبل الأطراف، على إحداث أثر قانوني معين، شريطة توافر جميع أركان انعقاد العقد، وشروط صحة انعقاده، وفقاً لما تقرره القواعد العامة.

وبعد عرض الاتجاه المؤيد للطبيعة العقدية للمفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض صريح، نخصص الفرع التالي لتوضيح اعتراض جانب من الفقه على هذه الطبيعة، والرد على هذا الاعتراض وفقاً لما يلي.

الفرع الثاني

اتجاه معارض للطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد تفاوض صريح والرد عليه

نذكر في هذا الموضع بعض الحجج والأسانيد التي استند إليها أصحاب الاتجاه المعارض للطبيعة العقدية للمفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض صريح، والرد على هذا الاعتراض، على النحو الآتي:

1 عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 274-273؛ سعود فواز ماجد الدرويش، مرجع سابق، ص 15-14؛ حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 853 و 850 و 846؛ أبحار حامد حبش، مرجع سابق، ص 55-53.

الفصل الأول الاعتراض على الصفة العقدية للمفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض صريح

يرى جانب من الفقه¹ بأن إضفاء الطبيعة العقدية على المفاوضات بصفة عامة، ما هو إلا استباق للأحداث المستقبلية للعقد النهائي، وبأنه من غير الداعي إقامة المسؤولية العقدية على المتفاوض الذي أخل بمبدأ حسن النية قبل انعقاد العقد بصورته النهائية؛ حيث لن يفلت المتفاوض من المحاسبة إذا ما وقع منه إخلال بعد انعقاد العقد النهائي. ومن زاوية أخرى، فإنه يتوجب عدم ربط نجاح انعقاد العقد النهائي بوجود مفاوضات من عدمه، فقد ينعقد العقد النهائي، رغم عدم دخول الأطراف في مفاوضات من الأساس، أو فشلهم في المفاوضات، فعلى أي أساس يتم إضفاء الصفة العقدية للمفاوضات؟

كما يعترض جانب آخر على ذلك أيضاً² بحجة أن الصفة العقدية للمفاوضات، من شأنها أن تجبر الأطراف على إبرام عقود قد لا يرتضونها، تنفيذاً لما آلت إليه المفاوضات، الأمر الذي من شأنه أن يخالف مبدأ حرية التعاقد الذي ينبغي أن يسود فترة المفاوضات.

1 شرف علي خالد بغيرات، مرجع سابق، ص ص 69-70.

2 ذات المرجع، ص 70.

الفصل الثاني الرد على الاعتراض

رد الاتجاه المؤيد للصفة العقدية للمفاوضات على هذه الاعتراضات¹، بالقول بأن فرض المسؤولية العقدية في حال الإخلال بمبدأ حسن النية أثناء فترة المفاوضات، لا يعني إجبار الأطراف على إبرام العقد النهائي، فالهدف هو إلزامهم بالتقيد بمبدأ حسن النية أثناء تفاوضهم، وليس لإجبارهم على إبرام العقد محل المفاوضة، وبالتالي، لا يوجد ما يخالف مبدأ حرية التعاقد. فالمتفاوض حر في الاستمرار أو العدول عن التفاوض في أي وقت شاء، على أن يكون ذلك في حدود حسن النية. كما أن هناك قواعد وضوابط أخرى من شأنها أن تحول دون حدوث مثل هذا الإجبار، كنظرية عيوب الإرادة، ومبدأ حرية التعاقد.

كما يتمسك هذا الاتجاه للرد على معارضي الصفة العقدية للمفاوضات بالقول بأنه " ليس من العدل إطلاق حرية الأطراف في التفاوض، وعدم تقرير مسؤولية عن القيام أو الامتناع عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف المقابل، إنما لابد من وجود مسؤولية وهي مسؤولية عقدية انطلاقاً من وجود عقد التفاوض". كما يرى هذا الاتجاه بأنه من المفترض أن يوجه هذا الانتقاد على وجود المسؤولية، لا على تكييفها، فيما إذا كانت عقدية أم تقصيرية، فهذا التكييف من وجهة نظرهم لا يغير من الأمر شيء، فهو لا يؤدي إلى إجبار الأطراف على إبرام العقد النهائي². بل على العكس من ذلك، قد يؤدي إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية إلى اضطراب أحد الأطراف بالفعل على إبرام العقد النهائي محل التفاوض لتجنب تحمل عبء التعويض

1 انظر مجمل الأسانيد التي استند إليها هذا الاتجاه لتأييد الصفة العقدية للمفاوضات شرف علي خالد بعيرات، مرجع سابق، ص ص 72-70؛ عبد العزيز المرسي حمود، مرجع سابق، ص 274.

2 شرف علي خالد بعيرات، مرجع سابق، ص ص 71-70.

وفقاً لقواعد هذه المسؤولية، والتي تلزم مرتكب الفعل الضار بتعويض المتضرر عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع؛ بخلاف قواعد المسؤولية العقدية التي لا تلزم بالتعويض إلا عن الخطأ العقدي المباشر المتوقع. فضلاً عن الصعوبة التي يواجهها المتفاوض المتضرر من ناحية إثبات حدوث خطأ من المتفاوض الآخر؛ وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي لحق به، بخلاف الوضع فيما لو اعتبرنا هذا الخطأ خطأً عقدياً بموجب عقد التفاوض، فلا توجد صعوبة في إثبات الخطأ العقدي فهو قائم بمجرد إثبات عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه العقدي أو تنفيذه لهذا الالتزام بشكل مغلوط أو جزئي. وهذا ما قد يجعل المتفاوض يفضل إبرام العقد النهائي مع الطرف المقابل له على مطالبته بالتعويض عما صدر منه من خطأ تقصيري أثناء سير المفاوضات تجنباً في الدخول معه في نزاع قد يفشل في إثبات دعواه، مما يزيد من تضرره¹.

كما يؤدي إضفاء الصفة العقدية على المفاوضات - سواء كانت مصحوبة باتفاق صريح أم ضمني - إلى المحافظة على التوازن العقدي للعقد المراد إبرامه، لما تولده هذه الصفة من شعور لدى الطرفين بالزامية المحافظة على هذا التوازن، ليس فقط عند تحديدهم لشروط وأحكام التفاوض، بل عند انتقالهم لمرحلة إبرام العقد، ولغاية تنفيذ العقد النهائي، وبالتالي ترسيخ فكرة العدالة العقدية. كما أن لهذه الصفة دور مهم في تقنين الالتزامات التي تتطلب طبيعتها أن يتم توثيقها في اتفاق خاص، نظراً لأهميتها لدى الطرفين، كالالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، والالتزام بعدم الدخول في مفاوضات موازية، مما يسهل على الطرف المتضرر إثباتها عند إنكار الطرف المخل بها².

1 راجع الأسباب التي يستند إليها الاتجاه الفقهي المؤيد للطبيعة العقدية للمفاوضات بموجب عقد ضمني في الصفحات 25-27 من هذا البحث.

2 شرف علي بعبيرات، مرجع سابق، ص 72-71؛ حمدي محمود بارود، مرجع سابق، ص 845؛ أبجار حامد حبش علي، مرجع سابق، ص 36.

وأخيراً، نرى بأن الحجج والأسانيد التي ساقها الاتجاه المؤيد للطبيعة العقدية للمفاوضات -المصحوبة باتفاق صريح أم ضمني- أكثر منطقية وعدلاً من أسانيد الاتجاه المؤيد للطبيعة المادية للمفاوضات. لذلك أؤيد من يرى¹ بأنها كافية لدحض هذه الطبيعة.

الخاتمة

تم التوصل في هذا البحث إلى بعض النتائج والتوصيات نوجزها على النحو الآتي:

أولاً: النتائج

1. يعتبر مبدأ حسن النية في العقود من النظام العام في القانون المدني الفرنسي، ويترتب على ذلك، عدم جواز اتفاق الأطراف بداءةً على إعفاء أحد الأطراف أو كلاهما من مقتضيات وأحكام هذا المبدأ في أي مرحلة من مراحل العقد.
2. قد ينشأ عقد تفاوض ضمني بين الأطراف أثناء سير المفاوضات بمجرد صدور قبول مطابق من المتفاوض الآخر للإيجاب بالتفاوض الصادر من الطرف الراغب في الدخول معه في مفاوضات جدية بخصوص عقد ما، أو في الحالة التي تصبح فيها المفاوضات منتظمة؛ ومستمرة مدة معقولة من الزمن؛ ومتقدمة بحيث تصل إلى أقرب مستوى لانعقاد العقد النهائي بما يعكس وجود نية مشتركة وجادة بين الطرفين في إجراء تنظيم تعاقدى للمفاوضات الجارية بينهما؛ أو في الحالة التي يصدر فيها أي تصرف أو فعل مشترك من الطرفين يمكن أن يستدل منه على وجود اتفاق ضمني وجاد بينهما على التفاوض بشأن عقد ما، ففي مثل هذه الحالات، تعتبر طبيعة المفاوضات عقدية، وعلى أساس ذلك تطبق بشأنها قواعد المسؤولية العقدية، وفيما عدا ذلك تعتبر المفاوضات غير المصحوبة باتفاق صريح مجرد أعمال مادية لا ترتب

1 محمد أحمد محمود العكام، مرجع سابق، ص 45.

أية آثار قانونية، ومن ثم تطبق بشأنها قواعد المسؤولية التقصيرية.

3. يتضح عدم مواكبة المشرع الإماراتي للتطور الحاصل في بعض التشريعات الغربية كالقانون المدني الفرنسي والإيطالي وغيرها؛ والتي تفرض صراحةً على أطرافها الالتزام بحسن النية في مرحلتى المفاوضات وإبرام العقد.

4. يتضح وجود ازدواجية في تطبيق أحكام المسؤولية القانونية على المفاوضات في القضاء الإماراتي، حيث يطبق على المفاوضات غير المصحوبة باتفاق صريح أحكام المسؤولية التقصيرية بغض النظر عن نشوء عقد تفاوض ضمني بين الطرفين من عدمه، بينما يطبق على المفاوضات المصحوبة باتفاق صريح ومكتوب على تنظيم المفاوضات أحكام المسؤولية العقدية.

5. نرى بأن كل ما تم التوصل إليه بخصوص أصل وطبيعة مرحلة المفاوضات ينسحب أيضاً إلى مرحلة إبرام العقد. ومما يؤكد منطقية ذلك هو الدور المشترك الذي تقوم به هاتين المرحلتين من ناحية تشكيل وتحديد معالم العقد النهائي. كما أنه من البديهي أن تأخذ مرحلة إبرام العقد نفس طبيعة المفاوضات، باعتبارها مرحلة تكميلية يتم فيها استكمال ما تم التوصل إليه في مرحلة المفاوضات. وبالتالي إذا صاحبت هذه المفاوضات عقد تفاوض صريح أم ضمني، وأصبحت طبيعتها بموجب هذا العقد عقدية، فإنه من الطبيعي، والمنطقي أيضاً، أن تكون طبيعة المرحلة التي تتبعها وهي مرحلة إبرام العقد عقدية أيضاً والعكس.

ثانياً: التوصيات

يهدف المساهمة في سد النقص التشريعي فيما يخص تنظيم مبدأ حسن النية في مرحلتى المفاوضات وإبرام العقد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي بدولة الإمارات، قمت بصياغة بعض المواد المقترحة التي أتطلع إيرادها في الأحكام العامة للعقود لهذا القانون، وهي كالآتي:

مادة رقم (1) طبيعة المراحل السابقة على التعاقد

تكتسب المفاوضات الطبيعة العقدية، بمجرد نشوء عقد تفاوض صريح أم ضمني بين الطرفين لتنظيم أعمال وإجراءات المفاوضات الجارية بينهم حول إبرام عقد معين. وتندسب هذه الطبيعة العقدية للمرحلة اللاحقة لهذه المفاوضات وهي مرحلة إبرام العقد.

مادة (2) عقد التفاوض¹

يعتبر عقد التفاوض عقداً قائماً بذاته، يتكون بمجرد تلاقي إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وبمقتضاه يلتزم الأطراف أثناء المفاوضات وإبرام العقد بالتعامل بما يتفق وحسن النية.

مادة رقم (3) حالات سوء النية في مرحلة المفاوضات²

1. للأطراف حرية التفاوض ولا يسألون عند عدم التوصل إلى اتفاق.
2. مع ذلك، يسأل المتفاوض عما لحق بالطرف الآخر من أضرار نتيجة سوء نيته.
3. ويعد من قبيل سوء النية، على سبيل المثال لا الحصر، قيام طرف في المفاوضة بإشاعة آمال كاذبة تبعث ثقة زائفة لدى الطرف الآخر في إبرام العقد محل التفاوض بالرغم من نيته عدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر، أو قطع المفاوضات المتقدمة فجأة ودون مبرر، أو التفاوض لمجرد التسلية أو الدعاية أو لاستطلاع السوق دون وجود نية حقيقية في التعاقد، أو اعتماد أسلوب التسويف وإطالة مدة التفاوض مع العلم بصعوبة الوصول إلى اتفاق، أو طرح أفكار غامضة

1 الشطر الثاني من هذه الفقرة مأخوذ من حكم المادة (1337) من القانون المدني الإيطالي على النحو المشار إليه في هامش صفحة 15 من هذا البحث.

2 تم إضافة حكم مشابه لحكم المادة (5/2) من مبادئ توحيد قواعد التجارة الدولية، والمادة 1-1-15 من مبادئ اليونيدروا -المشار إليها في هامش صفحة 15 من هذا البحث- مع إضافة بعض التعديل عليها في الفقرتين الثانية والثالثة منها.

أثناء سير المفاوضات تؤدي إلى تشتت أفكار الطرف الآخر أو تقديم اقتراحات من الصعب تحقيقها مما يؤدي إلى فشل التفاوض.

مادة رقم (4) بطلان العقد النهائي المبرم بسوء نية⁽¹⁾

يعتبر باطلاً كل عقد نهائي تم إبرامه بين طرفين على غرار مجريات المفاوضات العقدية، وترتب عليه منح ميزة زائدة، وغير عادلة لطرف على حساب الطرف الآخر، نتيجة استغلال هذا الطرف -الذي تقررت له هذه الميزة- لظروف المتفاوض الآخر أثناء سير المفاوضات، كاستغلال حالة احتياجه، أو ضائقته المالية، أو حالة استعجاله، أو جهله المبرر بمحل التفاوض، أو عدم قدرته على التفاوض، ليتم على أساسها فرض شروطه في العقد النهائي.

مادة رقم (5) حظر الإعفاء من حسن النية

لا يجوز للأطراف الاتفاق على إعفاء أحدهما أو كلاهما من الالتزام بالتفاوض بحسن نية وما يتفرع عنه من التزامات خلال مرحلي المفاوضات وإبرام العقد، وإلا اعتبر هذا الاتفاق باطلاً لمخالفته النظام العام.

مادة رقم (6) المسؤولية العقدية لعقد التفاوض²

تطبق أحكام المسؤولية العقدية عند الإخلال بأي من التزامات عقد التفاوض

1 الحكم مأخوذ من المادة العاشرة الواردة في مجموعة المبادئ العامة للعقود التجارية الدولية- وقد تم إجراء تعديل عليه- حيث نصت هذه المادة على الآتي: "يعتبر باطلاً كل عقد يعطي فيه ميزة زائدة وغير عادلة لطرف خصوصاً من جراء استغلال الطرف الآخر بطريقة غير مشروعة، وحالة الاحتياج أو الضائقة الاقتصادية أو الحاجات المستعجلة أو عدم التبصر أو الجهل أو القدرة على التفاوض مع الطرف الآخر". أشار له رعد أحمد عبد ربه اللوزي، مرجع سابق، ص ص 67-68.

2 الشطر الأخير من مقترح هذه المادة مأخوذ من حكم المادة (1112) من القانون المدني الفرنسي المعدل بمرسوم أكتوبر لسنة 2016 أنفة الذكر.

الصريح أم الضمني أثناء مرحلتي المفاوضات وإبرام العقد، ولا يجوز للقاضي عند تقدير التعويض بأي حال من الأحوال الحكم بانعقاد العقد النهائي أو الحكم بتعويض خسارة المزايا التي كانت منتظرة من العقد الذي لم يتم إبرامه.

تم بتوفيق الله وبحمده،

قائمة المراجع

أولاً: الكتب العلمية

1. جهاد صالح العتيبي، القواعد القضائية في شرح القانون المدني- العقد، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، الطبعة الأولى، 2014.
2. مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، كلية الحقوق - جامعة طنطا، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010.

ثانياً: الرسائل العلمية

1. رسائل الدكتوراه

1. رعد أحمد عبد ربه اللوزي، التنظيم القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في القانون الأردني، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية - كلية الدراسات العليا، الأردن، 2016.
2. محمد أحمد محمود العكام، العدول عن إبرام العقد في مرحلة التفاوض وأثره القانوني، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية - كلية الدراسات العليا، الأردن، 2015.

2. رسائل الماجستير

1. أبحار حامد حبش علي، المسؤولية المدنية عن قطع المفاوضات العقدية، رسالة ماجستير، جامعة الإسراء الخاصة - كلية الحقوق، الأردن، 2015.
2. خالد صقر أبو زهرة، التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في فلسطين: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت - كلية الدراسات العليا، فلسطين، 2021.
3. سعود فواز ماجد الدرويش، مبدأ حسن النية في عقد التأمين في النظام

- السعودي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية- كلية الدراسات العليا، الأردن، 2016.
4. شرف علي خالد بعيرات، آثار الإخلال بمبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات العقدية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك- كلية القانون، الأردن، 2018.
5. لى محمد أحمد المبيضين، التزامات المفاوض في عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة - عمادة الدراسات العليا، الأردن، 2018.
6. مبارك محمد آل فطيح، دور القاضي في تطبيق مبدأ حسن النية في العقد، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا، الأردن، 2010.
7. هدى بن يوب، مبدأ حسن النية في العقود، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية-قسم الحقوق، الجزائر، 2013.

ثالثاً: المجالات العلمية

1. أم كلثوم صبيح محمد و د. أسماء صبر علوان، الالتزام بالإعلام في ضوء تعديلات القانون الفرنسي بموجب مرسوم 10 أكتوبر 2016، المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية، مجلة محكمة، ع 19، 2018.
2. إيناس مكي عبد نصار، التفاوض الالكتروني: دراسة مقارنة في ظل بعض التشريعات العربية المعاصرة، المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الإنسانية، الناشر: جامعة بابل، العراق، مجلة محكمة، مج 21، ع 3، 2013.
3. توحيدة محمد يوسف السيد، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد: دراسة قانونية، المصدر: مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية، الناشر: مركز بحوث

ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البليدة 2، السودان، مجلة محكمة، ع 5، 2021.

4. حمدي محمود بارود، المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها: مبدأ حسن النية ومقتضياته- دراسة تأصيلية تحليلية، المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة- شئون البحث العلمي والدراسات العليا، فلسطين، مجلة محكمة، مج 16، ع 1، 2008.

5. سماح جبار، حسن النية في التفاوض على العقود، المصدر: دراسات، الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، مجلة محكمة، ع 48، 2016.

6. عبد العزيز المرسي حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدية: " دراسة مقارنة"، المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق، مصر، مجلة محكمة، مج 10، ع 20، 2001.

7. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التركي، أثر مبدأ حسن النية في العقود التجارية، المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية، الناشر: عبد الفتاح محمود ادريس، مصر، مجلة محكمة، مج 6، ع 63، 2017.

رابعاً: المواقع الالكترونية

1. موقع محامو الإمارات.
2. موقع قوانين الشرق.
3. دار المنظومة بموقع مكتبة جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

خامساً: القوانين

1. قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1985، نشر بتاريخ 21 مارس 1985 في الجريدة الرسمية، العدد (158)، والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 1/1987 بتاريخ 14/2/1987 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 30/2020 بتاريخ 27/09/2020.
2. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الصادر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 هـ (16 يوليو سنة 1948) وفقاً لأحدث تعديلاته له- نسخة من إعداد وزارة المالية، القطاع: شئون اجتماعية وثقافية- الأحوال الشخصية، نوع الوثيقة: قوانين ولوائح -قوانين، منشورات قانونية- أرشيف رقمي، تاريخ الاطلاع على شبكة الانترنت: 17/11/2024، على الرابط: <https://manshurat.org/node/72413>.
3. القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2645 على الصفحة 2 بتاريخ 1/8/1976 والساري بتاريخ 1/1/1977 وتعديلاته، منقح ومحدث حتى سنة 2024، موقع حُماة الحق للمحاماة، تاريخ الاطلاع على شبكة الانترنت 17/11/2024، على الرابط: <https://jordan-lawyer.com/2010/07/11/jordan-civil-law-with-all-amendments/>.
4. ترجمة محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 1100 إلى 1231-7 من القانون المدني الفرنسي، منشورات الحلبي، بيروت- لبنان، 2018.

سادساً: أحكام المحاكم العليا

1. أحكام المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. أحكام محكمة نقض أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. أحكام محكمة النقض المصرية.
4. أحكام محكمة التمييز الأردنية.
5. أحكام محكمة النقض الفرنسية.